09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI**
RECTE.(S)	: GIOVANE PASQUALITO FIALHO
ADV.(A/S)	: CAETANO CUERVO LO PUMO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S)	: UNIÃO
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. USO DE CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. RESERVA DE VAGA OU ESTABELECIMENTO DE COTAS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I – Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, conhecer e negar provimento ao recurso extraordinário, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto.

Brasília, 9 de maio de 2012.

RICARDO LEWANDOWSKI - RELATOR

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009875.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR	**: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI**
RECTE.(S)	: GIOVANE PASQUALITO FIALHO
ADV.(A/S)	: CAETANO CUERVO LO PUMO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S)	: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S)	: UNIÃO
ADV.(A/S)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO **RICARDO LEWANDOWSKI** (RELATOR): Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu ser constitucional o programa de ação afirmativa, estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, que instituiu o sistema de "cotas" com reserva de vagas como meio de ingresso em seus cursos de nível superior.

No origem, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Reitor da UFRGS. Narrou que inscreveu-se no vestibular 2008/01 da citada Universidade para o curso de Administração. No entanto, não alcançou classificação suficiente em exame vestibular para ser admitido no curso pleiteado, não obstante tenha logrado pontuação maior do que alguns candidatos que ingressaram no mesmo curso pelo sistema de reserva de vagas destinadas aos estudantes egressos do ensino público e aos estudantes negros egressos do ensino público.

Afirmou ter sido informado de que, com base nos termos da Decisão 134/2007, exarada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

> "*das 160 vagas disponibilizadas, 30% (trinta por cento) estariam reservadas a candidatos privilegiados em razão de sua etnia e condição social e 10 (dez) vagas a candidatos indígenas*" (fl. 05).

Alegou que

> "*tais decisões, como esta, devem ser encaradas como verdadeiro pacto de mediocridade – para os estudantes da rede pública, sabidamente menos preparados na medida em que foram prejudicados por absoluta incúria do Poder Executivo em lhes prover uma formação humanística e propedêutica decente, em detrimento de estudantes oriundos do ensino médio particular, demonizando, portanto, o conhecimento oriundo de estabelecimentos particulares comprometidos com o ensino, em prol de uma rede pública falida.*
>
> *Quanto à discriminação étnica, o absurdo é ainda maior, pois o raciocínio subjacente é que a Universidade Pública, paga por todos, é 'loteada' entre os que possuem ascendência derivada dos indivíduos da raça negra e índios, o que é um despautério*" (fl. 06).

Sustentou, nessa esteira, ser

> "*artificial, esse critério, que ao invés de levar o aluno à Universidade, levou a Universidade ao aluno, tornando lícito supor que produzirá, em breve futuro, duas categorias de profissionais: engenheiros, médicos, advogados, juízes e promotores que lograram ingressar na Universidade sem mérito, o que pressupõe não conter formação propedêutica suficiente ao acompanhamento do curso, e os que o fizeram com mérito, sendo previsível a futura discriminação que os primeiros sofrerão mercê do baixo desempenho que terão em suas profissões, salvo se, também, para as profissões for criado um 'sistema de cotas' que sequer tem respaldo de Lei ou Emenda Constitucional*" (fl. 08).

Destacou que

> "*sob outro aspecto, pelo fato de impor distinção de tratamento*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

> *com base em critério étnico, incorre em verdadeiro crime de racismo, o qual é igualmente vedado pela Constituição da República*" (fl. 09).

Argumentou, ademais, que o Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao instituir o sistema de cotas no vestibular, extrapolou os limites de sua competência, já que por meio da Resolução 134/2007 teria legislado sobre o tema.

Entendeu, nessa linha, que

> "*matérias relativas às diretrizes e bases da educação nacional só podem ser tratadas pela legislação federal, conforme determina o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição (...)*" (fl. 18).

Acrescentou, com base no art. 211, § 1º, da Constituição Federal, caber à União organizar o sistema federal de ensino, assim como exercer, em matéria educacional, função distributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade no ensino.

Quanto à ofensa ao art. 5º, *caput*, da Lei Maior, asseverou que

> "*o Impetrado desrespeitou a interdição constitucional da discriminação. Em primeiro lugar porque criou distinção arbitrária em favor de concorrentes, ao vestibular, oriundos do ensino público médio ministrado por estabelecimentos escolares públicos e, em o fazendo, as normas impugnadas elegeram um discrímen fundado em atributo pessoal (a origem escolar), o que é vedado pela Lei Fundamental. Em segundo lugar, porque discriminam candidatos ao vestibular com base em características extrínsecas dos concorrentes – a cor da pele. Alunos carentes ou pobres que se autodeclarem 'negros' levam vantagem sobre os carentes ou pobres 'brancos' e 'pardos', já que podem ingressar no ensino superior estadual com notas mais baixas do que estes últimos*" (fls. 26/27).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

Já quanto à ofensa aos artigos 206, I, e 208, V, da Carta Magna, aduziu ser o

> "*mérito a única medida capaz de garantir a igualdade de acesso ao ensino, sobretudo ao ensino superior, onde o ingresso se faz por concurso público de provas*" (fl. 29).

Alegou, igualmente, que os percentuais de vagas reservadas pela legislação impugnada não são proporcionais e razoáveis; ao contrário, são excessivos e desarrazoados (fl. 33).

Afirmou, ainda, que

> "*há sérios riscos de chegarmos à deflagração de algum tipo de ódio racial. Dirão, é certo, os defensores das cotas, que esse é o preço a pagar para alcançar a igualdade 'real'. Esse preço, todavia, é alto demais. Nossa Constituição não autoriza pagá-lo pois há, sem dúvida alguma, medidas menos dramáticas e menos estigmatizantes para alcançar a igualdade material*" (fl. 35).

Em decisão de fls. 283-285, o juízo de 1º grau concedeu a segurança, por entender inconstitucional o sistema instituído pela UFRGS.

Contra essa decisão, a mencionada Universidade interpôs apelação - provida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, como já afirmado, entendeu ser constitucional o programa de ação afirmativa, estabelecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, que instituiu o sistema de "cotas" com reserva de vagas como meio de ingresso em seus cursos de nível superior.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

> "*DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES AFIRMATIVAS. 'COTAS' NAS UNIVERSIDADES. CRITÉRIO RACIAL.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

DISCRIMINAÇÃO. ISONOMIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MÉRITO UNIVERSITÁRIO.

1.POLÍTICAS AFIRMATIVAS. Conjunto de políticas públicas e privadas, tanto compulsórias, quanto facultativas ou voluntárias, com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e outras intolerâncias correlatas. Técnicas que não se subsumem ao sistema de cotas, ainda que com elas sempre relacionadas.

2.INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. Previsão expressa no Plano Nacional de Direitos Humanos, no Plano Nacional de Educação e nas Leis nº 10.558/2002, que criou o programa 'Diversidade na Universidade' e Lei nº 10.678/2003, que criou Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Autorização, por via legal, para implementação, pelo Poder Executivo, de políticas afirmativas. Previsão em tratados internacionais.

3. CONSTITUIÇÃO. Previsão expressa no tocante à mulher (art. 7º, XX) e a portadores de necessidades especiais (art. 37, VIII), a sinalizar baliza fundamental para aplicação do princípio da igualdade jurídica. Legislação infraconstitucional que estabeleceu cotas para candidaturas de mulheres, para portadores de necessidades especiais em concursos públicos e dispensa de licitação.

4. TRATADOS INTERNACIONAIS. Reconhecimento pelo Brasil da competência do Comitê Internacional para eliminação da discriminação racial. Internalização da Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial. Recepção dos tratados internacionais anteriores à EC 45/2002, com statussupralegal ou de materialmente constitucionais, jurisprudência ainda não definida no STF, mas a indicar a possibilidade de constituírem 'bloco de constitucionalidade', a ampliar núcleo mínimo de direitos e o próprio parâmetro de controle de constitucionalidade.

5. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revisão dos parâmetros clássicos, de forma a reconhecer sua dupla faceta: a) proibição de diferenciação, em que 'tratamento como igual significa direito a um tratamento igual'; b) obrigação de diferenciação, em que tratamento como igual significa 'direito a um tratamento especial'. Rompimento com a visão clássica, de forma que a igualação jurídica se faça, constitucionalmente, como conceito positivo de condutas promotoras

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

desta igualação.

6. DISCRIMINAÇÃO. Conceito internalizado pelo Decreto nº 65.810/69, reconhecendo diferenciações legítimas e afastando propósitos e efeitos de anular reconhecimento de direitos em pé de igualdade em razão de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Quadro cultural brasileiro complexo no que diz respeito ao reconhecimento da existência do próprio racismo, com a ideologia do 'branqueamento' e o 'mito da democracia racial'. Informes internacionais questionando a dificuldade do aparelho estatal em reconhecer e promover atitudes antidiscriminatórias. Reconhecimento, por outro lado, de que a regra aparentemente neutra pode produzir discriminação, que a Constituição proíbe.

7. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. Art. 207, V, CF. Previsão constitucional regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo como norte 'as normas gerais da União' e do 'respectivo sistema de ensino', podendo ser ampliadas ou reduzidas as vagas ofertadas.

8. SISTEMA MERITÓRIO. A previsão constante no art. 208, V da Constituição não estabeleceu o 'mérito' como critério único e decisivo para acesso ao ensino superior, nem constitucionalizou o sistema do Vestibular. Existência de 'nota de corte', a demonstrar que o mérito é conjugado com outros critérios de índole social e racial. Inexistência de 'mérito' em abstrato.

9. AUTODECLARAÇÃO. Critério que não é ofensivo nem discriminatório em relação aos 'negros', porque: a) já é adotado para fins de censo populacional, sem objeções; b) utilizado amplamente no direito internacional; c) guarda consonância com os diplomas legais existentes; d) constitui reivindicação dos próprios movimentos sociais antidiscriminação.

10. DISCRÍMEN RAÇA. Possibilidade admitida quando agir 'não para humilhar ou insultar um grupo racial, mas para compensar desvantagens impostas contra minorias'. Congruência com os ditames constitucionais de vedação ao racismo, na ordem interna e externa, de modo a indicar: a) no aspecto negativo, a necessidade de impedir qualquer conduta, prática ou atitude que incentive, prolifere ou constitua racismo; b) no aspecto positivo, um mandamento de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

otimização de medidas cabíveis e possíveis para erradicação de tal prática. Inexistência de 'raças' a indicar, contudo, a necessidade de censura ao 'racismo'. Inteligência da decisão do STF no HC 82.424/RS. Preconceito, no Brasil, de fundo distinto daquele praticado nos EUA e África do Sul ('preconceito de marca' ao invés de 'preconceito de origem'), a indicar a inaplicabilidade, aqui, das discussões sobre percentuais de genes africanos, europeus ou indígenas.

11. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Aplicação aos atos de todos os poderes públicos, vinculando legislador, julgador e administrador, mas com extensão e intensidade distintas conforme se trate de atos legislativos, da administração ou da jurisdição. Limites de 'conformação' do administrador e do legislador a reduzir a análise de todas as possibilidades de escolhas postas à disposição. Verificação de: a) adequação, que não constitui o dever de escolher o meio mais intenso, melhor e mais seguro, mas sim a anular o ato somente quando a inadequação for evidente e não for, de qualquer modo, justificável; b) necessidade, em relação ao meio eficaz e menos desvantajoso para os cidadãos; c) proporcionalidade em sentido estrito, comparando a importância da realização do fim e a intensidade da restrição de direitos fundamentais. Metas fixadas para educação nacional pelo Legislativo com duração de dez anos, passíveis de revisão. Não comprovação de que as premissas para instituição de critérios de 'inclusão social'- ampliação do acesso para estudos de ensino público e autodeclarados negros, promoção da diversidade étnico-racial no ambiente universitário, educação de relações étnico-raciais - não são critérios adequados, necessários e proporcionais para os fins constitucionais de repúdio ao racismo, redução das desigualdades sociais, pluralismo de ideias, garantia de padrão de qualidade do ensino, defesa e valorização da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, valorização da diversidade étnica e cultural e promoção do bem de todos, 'sem preconceitos de raça e cor e quaisquer outras formas de discriminação'. Percentuais de cotas que não constituem patamar elevado, seja porque 87% da oferta de vagas vem do ensino público médio e fundamental, seja porque a população negra brasileira é superior ao percentual estabelecido nas cotas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

> *Reconhecimento de que os programas deixam sempre à disputa livre da maioria 'a maior parcela de vagas', como forma de 'garantia democrática do exercício de liberdade pessoal e realização do princípio da não-discriminação' (Carmen Lucia Antunes)*" (fl. 390).

Neste Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, **a**, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5º, *caput*, 22, XXIV, 206, I, e 208, V, da mesma Carta, bem como ao princípio da proporcionalidade. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da reserva de vagas, como forma de ação afirmativa, estabelecido pela UFRGS.

No tocante à repercussão geral, em preliminar específica, aduz-se, em síntese, que o tema possui *"relevância do ponto de vista social e jurídico"* (fl. 396).

No mérito, colaciona os mesmos argumentos trazidos na peça inicial do mandado de segurança.

Em contrarrazões do RE, a UFRGS alega o descabimento do recurso. Entende, com base na Súmula 283 do STF, que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento e o recurso não abrange todos eles, uma vez que o acórdão é fundamentado nos arts. 3º, III, IV, 4º, VII, 5º, *caput*, XLVII, 206, III, VII, 207, 208, V, 215 e 216, da Carta Maior, porém o recorrente aponta transgredidos, tão somente, os arts. 5º, *caput*, 22, XVIV, 206, I, e 208, V, todos da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, argumenta que o recorrente não consegue demonstrar a violação das normas constitucionais invocadas.

Assevera, além disso, que

> "o *programa de cotas raciais e sociais deve ser visto como uma tentativa de dar a população negra e aquela de baixa renda outra autoestima, marcada não apenas por referências no esporte, na música*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

> *ou nas artes, mas também por referências nas profissões liberais, nas empresas, nos cargos públicos de comando, enfim, nos diversos espaços sociais. Para isso, transitoriamente (e o programa de cotas é e deve ser transitório) a Universidade deve acelerar a formação de lideranças negras para um novo ambiente, marcado pela diversidade nos mais diversos segmentos sociais.*
>
> *O programa de cotas é transitório, serve de passagem, e deverá ser utilizado até que não reste mais nenhuma dúvida quanto ao fato de que efetivamente todos são iguais, em especial quando se fala em oportunidades de crescimento e aprimoramento e quando o ensino fundamental e médio do sistema público de ensino tiver a mesma qualidade do privado*" (fls. 461 - 461-v).

Por fim, espera que o recurso não seja conhecido ou, no mérito, seja desprovido (fl. 462).

Em despacho de fl. 469, solicitei a manifestação do Procurador-Geral da República que opinou pelo não provimento do recurso (fls. 471-475).

Em relação à constitucionalidade do conteúdo do sistema de cotas, afirmou a PGR que

> "*a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e de baixa renda, negros ou pardos, há que se ressaltar consideração importante ao princípio da igualdade, traduzido na seguinte frase de Rui Barbosa:*
>
> > *'A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real' (BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. Martin Claret: São Paulo, 2003, pág. 19)*" (fls. 474-475).

Às fls. 478-483, convoquei Audiência Pública para ouvir o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria de políticas de ação afirmativa no ensino superior.

Em decisão de fls. 494-495, entendi que a controvérsia possui repercussão geral, pois a questão constitucional trazida aos autos ultrapassa o interesse subjetivo das partes que atuam neste feito.

Assentei, ademais, a questão constitucional apresenta relevância do ponto de vista jurídico e a interpretação a ser firmada por esta Corte poderá autorizar, ou não, ações desse tipo pelas universidades.

Além disso, evidencia-se a repercussão social, porquanto a solução da controvérsia em análise poderá ensejar relevante impacto sobre políticas públicas que objetivam, por meio de ações afirmativas, a redução de desigualdades para o acesso ao ensino superior.

À fl. 500, esta Corte decidiu reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

> "*CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS ('COTAS'). AÇÕES AFIRMATIVAS. RELEVÂNCIA JURÍDICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL*".

Deferi, ainda, o ingresso da União, como terceiro interessado, no feito.

É o relatório necessário.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009876.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

O SENHOR MINISTRO **RICARDO LEWANDOWSKI** (RELATOR): Inicialmente, afasto a preliminar de não cabimento do extraordinário levantada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela suposta ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido.

Como se verifica, até mesmo pelas passagens destacadas no relatório, o recorrente impugnou o sistema de cotas, trazendo diversos fundamentos a fim de contribuir para o deslinde desse relevante tema constitucional.

No mérito, assim como fez o acórdão recorrido, afasto a alegada necessidade de lei formal para disciplinar a matéria, que está inserida no âmbito da autonomia universitária.

Com efeito, a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não dispõe sobre os critérios que devem ser utilizados na seleção de estudantes, deixando esse estabelecimento a cargo das universidades, como se percebe da leitura do art. 51, *in verbis*:

> *"Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino*".

Ademais, embora não exista lei específica tratando do sistema de cotas, há toda uma base normativa legal que autoriza o uso de ações afirmativas, como a utilização de critério étnico-racial na seleção para ingresso no ensino superior, conforme ressaltei na ADPF 186/DF, de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009877.

minha relatoria.

Nesse sentido, vale também destacar as razões trazidas pelo voto condutor do acórdão recorrido, que transcrevo, por oportuno:

> "(...)
>
> *A alegação de que não existe base legal, no ordenamento pátrio, é equivocada. É que desde o Primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do Decreto nº 1.904/1996, a questão das políticas afirmativas já estava incluída, restando reafirmada pelo governo brasileiro, quando participou da Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban (31-08 a 08-09-2001). A Declaração de Durban, de 2001, da qual o Brasil foi um dos signatários, reconheceu, no texto final (disponível no site http://www.mulheresnegras.org/doc/Declafinal.pdf) que o combate ao racismo é 'responsabilidade primordial dos Estados' (parágrafo 99), instando os governos a adotar inclusive 'programas de ações afirmativas ou medidas de ação positivas, para promoverem o acesso de indivíduos que são ou podem ser vir a ser vítimas de discriminação racial nos serviços sociais básicos, incluindo ensino fundamental' (parágrafo 100) e tomar medidas que capacitem estudantes 'independente de raça, cor, descendência, origem étnica ou nacional' a frequentarem 'instituições de ensino superior' (parágrafo 123, item 'g'), além de assegurar ambiente escolar seguro e livre de racismo (parágrafo 123, item 'f'). Esta endossou, nos parágrafos 107 e 108, a importância de os Estados adotarem ações afirmativas para aqueles que foram vítimas de discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância correlata.*
>
> *Não sendo nova, pois, a questão, ela se encontra internamente incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, desde que o Decreto nº 65.810, de 08-12-1969, internalizou a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que previu, no art. 1º, parágrafo 4º, a adoção de 'discriminação positiva', no sentido de que medidas especiais sejam*
>
> *'tomadas com o objetivo precípuo de assegurar, de forma*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009877.

> *conveniente, o progresso de certos grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições, não serão consideradas medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos os seus objetivos'.*
>
> *O marco normativo, pois, do conceito de 'discriminação' está balizado pelos parâmetros fixados naquela Convenção Internacional".*

No mais, os outros argumentos levantados pelo recorrido foram analisados na ADPF 186/DF, em que considerei a constitucionalidade: (i) das políticas de ação afirmativa, (ii) da utilização dessas políticas na seleção para o ingresso no ensino superior, especialmente nas escolas públicas, (iii) do uso do critério étnico-racial por essas políticas, (iv) da autoidentificação como método de seleção e (v) da modalidade de reserva de vagas ou de estabelecimento de cotas.

Por todas essas razões, tendo em vista que o critério utilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – reserva de 30% de vagas para egressos do sistema público, destinando, desse total, 50% para autodeclarados negros – se coaduna com as premissas estabelecidas na ADPF 186/DF, conheço do recurso extraordinário, mas lhe nego provimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2009877.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, em função do exaustivo debate, lembrado pelo eminente Relator, ao julgamento da ADPF nº 186, talvez fosse suficiente reportar-me ao belíssimo voto do eminente Relator e dizer que estou o acompanhando, na íntegra, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Eu sou gaúcha, de Porto Alegre, fiz o meu curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Faculdade de Direito de Porto Alegre, com muita honra e orgulho. Presto uma homenagem à Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, Colega de turma da Ministra Ellen Gracie, inclusive, que foi a Redatora designada do acórdão. Então, trata-se de um acórdão lavrado do julgamento de um reexame necessário, remessa oficial e uma apelação em mandado de segurança, homenageio a Desembargadora Federal Maria Lúcia, sem prejuízo das belíssimas sustentações orais que ouvimos, na parte final do seu voto divergente, que prevaleceu.

Diz ela:

"No caso específico da UFRGS, o Edital do Concurso Vestibular 2008 estabelecera um percentual de 30% das vagas para egressos do sistema público, destinando, deste total, 50% para autodeclarados negros. Vale dizer, não havendo número de 'autodeclarados negros', as vagas continuavam para egressos do sistema público, não revertendo, automaticamente, para o acesso universal. Desta forma, no curso de Administração-Noturno," - a que objetivava o impetrante - "de um total de 160 vagas, 112 estavam destinadas para acesso universal e 48 para inclusão social, sendo destas 24 para autodeclarados negros. Não havia, pois, para candidato impetrante, o acesso às 160 vagas, se a sua colocação era 132ª. Sabia, pelo edital, que estavam disponíveis 112 vagas e não 160.

Desta forma, se há um número determinado de vagas reservado para candidatos provenientes do ensino público e para candidatos auto declarados

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2614415.

negros provenientes do ensino público, ninguém retira o lugar de ninguém, estando os cotistas, apenas, ocupando um espaço que lhes é de direito. Inexiste, pois, o alegado direito líquido e certo da parte impetrante.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa oficial."

Senhores Ministros, à luz da nossa Constituição Federal, diante desse sistema de cotas, observada a etnia racial, observada a origem do ensino público e a própria reserva para indígenas, entendo que o sistema instaurado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul guarda absoluta consonância com a Constituição da República, quando estabelece, como seu fundamento, a dignidade da pessoa humana e, ainda, diz constituir objetivo fundamental a erradicação da pobreza, marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Senhor Presidente, voto de acordo com o eminente Ministro Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2614415.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, egrégio Plenário, ilustre Representante do Ministério Público, senhores Advogados presentes e partes. Senhor Presidente, há duas regras de supradireito que se aplicam como uma luva no caso presente. A primeira delas é no sentido de que o Direito vive para o homem e não o homem para o direito, de sorte que o Direito tem de ser servil àquilo que se constata na vida humana.

Em segundo lugar, a máxima latina diz que **notoria non egent probatione**, ou seja, que os fatos notórios independem de prova. Ora, já no julgamento passado, nós afirmamos, com base em dados empíricos, que dificilmente o aluno que estuda em colégio público chega à Universidade Pública. Isto é constatável, **prima facie.**

De sorte que a solução adotada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul: de reservar trinta por cento das vagas oferecidas para cada curso aos alunos oriundos de escolas públicas, sendo que, deste percentual, metade é destinado a negros que tenham cursado pelo menos metade do ensino fundamental e todo o ensino médio em estabelecimento público de ensino, na realidade, assenta uma solução que exatamente converge para essa triste realidade de que o aluno de colégio público e aquele que tem uma descendência afro**,** ele tem dificuldades de acesso à universidade. Quanto a isso, restou pacífico no nosso último julgamento. Ora, essa solução consegue ser mais perfeita do que a integração étnico-racial, porque ela também leva em consideração a trajetória onerosíssima do estudante que cursa o ensino público fundamental, e que ele é deficitário em quantidade e também em qualidade. De sorte que a ideologia que gravitou em torno do voto sedimentado à unanimidade pelo Plenário, acerca da igualdade substancial - que é aquela que não seduz conquanto letra morta no papel,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2115487.

mas é uma igualdade que se baseia na realidade prática -, essa solução da Universidade do Rio Grande do Sul é exatamente aquela que permite, como dispõe o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, o acesso ao ensino universitário, segundo as capacidades de cada um.

Ainda que esses aspectos interdisciplinares não fossem suficientes - e já explorados com muito brilhantismo pelo eminente Ministro-Relator e pela ministra Rosa Weber - verifica-se aqui, na verdade, uma classificação que leva em conta essa trajetória da vida do aluno, que não encerra uma discriminação, mas, sim, uma classificação, que se denomina na doutrina norte-americana, benigna, como destaca o professor Erwin Chemerinski no seu livro sobre os princípios e as políticas na Constituição americana.

De sorte, Senhor Presidente, que, com esses breves fundamentos, uma vez que nós já tivemos oportunidade de destacar outros aspectos quando do julgamento das ações afirmativas, também destaco esse aspecto jurídico, estritamente jurídico, que a Ministra Rosa Weber realçou de que havia no edital um aviso - e o edital é a regra do concurso - de que estas vagas seriam reservadas, e entendo que o Recurso Extraordinário não mereça provimento, acompanho o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2115487.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também reitero quanto ao dito nas outras ações, na ADPF, acompanhando o voto do Relator, para negar provimento ao recurso.

1. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea *a*, da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

> *"DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES AFIRMATIVAS. 'COTAS' NAS UNIVERSIDADES. CRITÉRIO RACIAL. DISCRIMINAÇÃO. ISONOMIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MÉRITO UNIVERSITÁRIO. 1. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. Conjunto de políticas públicas e privadas, tanto compulsórias, quanto facultativas ou voluntárias, com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e outras intolerâncias correlatas. Técnicas que não se subsumem ao sistema de cotas, ainda que com elas sempre relacionadas. 2.INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. Previsão expressa no Plano Nacional de Direitos Humanos, no Plano Nacional de Educação e nas Leis nº 10.558/2002, que criou o programa 'Diversidade na Universidade' e Lei nº 10.678/2003, que criou Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Autorização, por via legal, para implementação, pelo Poder Executivo, de políticas afirmativas. Previsão em tratados internacionais. 3. CONSTITUIÇÃO. Previsão expressa no tocante à mulher (art. 7º, XX) e a portadores de necessidades especiais (art. 37, VIII), a sinalizar baliza fundamental para aplicação do princípio da igualdade jurídica. Legislação infraconstitucional que estabeleceu cotas para candidaturas de mulheres, para portadores de necessidades especiais em concursos públicos e dispensa de licitação. 4. TRATADOS INTERNACIONAIS. Reconhecimento pelo Brasil da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

competência do Comitê Internacional para eliminação da discriminação racial. Internalização da Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial. Recepção dos tratados internacionais anteriores à EC 45/2002, com status supralegal ou de materialmente constitucionais, jurisprudência ainda não definida no STF, mas a indicar a possibilidade de constituírem 'bloco de constitucionalidade', a ampliar núcleo mínimo de direitos e o próprio parâmetro de controle de constitucionalidade. 5. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revisão dos parâmetros clássicos, de forma a reconhecer sua dupla faceta: a) proibição de diferenciação, em que 'tratamento como igual significa direito a um tratamento igual'; b) obrigação de diferenciação, em que tratamento como igual significa 'direito a um tratamento especial'. Rompimento com a visão clássica, de forma que a igualação jurídica se faça, constitucionalmente, como conceito positivo de condutas promotoras desta igualação. 6. DISCRIMINAÇÃO. Conceito internalizado pelo Decreto nº 65.810/69, reconhecendo diferenciações legítimas e afastando propósitos e efeitos de anular reconhecimento de direitos em pé de igualdade em razão de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Quadro cultural brasileiro complexo no que diz respeito ao reconhecimento da existência do próprio racismo, com a ideologia do 'branqueamento' e o 'mito da democracia racial'. Informes internacionais questionando a dificuldade do aparelho estatal em reconhecer e promover atitudes antidiscriminatórias. Reconhecimento, por outro lado, de que a regra aparentemente neutra pode produzir discriminação, que a Constituição proíbe. 7. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. Art. 207, V, CF. Previsão constitucional regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo como norte 'as normas gerais da União' e do 'respectivo sistema de ensino', podendo ser ampliadas ou reduzidas as vagas ofertadas. 8. SISTEMA MERITÓRIO. A previsão constante no art. 208, V da Constituição não estabeleceu o 'mérito' como critério único e decisivo para acesso ao ensino superior, nem constitucionalizou o sistema do Vestibular. Existência de 'nota de corte', a demonstrar que o mérito é conjugado com outros critérios de índole social e racial. Inexistência de 'mérito' em abstrato. 9. AUTODECLARAÇÃO. Critério que não é ofensivo nem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

discriminatório em relação aos 'negros', porque: a) já é adotado para fins de censo populacional, sem objeções; b) utilizado amplamente no direito internacional; c) guarda consonância com os diplomas legais existentes; d) constitui reivindicação dos próprios movimentos sociais antidiscriminação. 10. DISCRÍMEN RAÇA. Possibilidade admitida quando agir 'não para humilhar ou insultar um grupo racial, mas para compensar desvantagens impostas contra minorias'. Congruência com os ditames constitucionais de vedação ao racismo, na ordem interna e externa, de modo a indicar: a) no aspecto negativo, a necessidade de impedir qualquer conduta, prática ou atitude que incentive, prolifere ou constitua racismo; b) no aspecto positivo, um mandamento de otimização de medidas cabíveis e possíveis para erradicação de tal prática. Inexistência de 'raças' a indicar, contudo, a necessidade de censura ao 'racismo'. Inteligência da decisão do STF no HC 82.424/RS. Preconceito, no Brasil, de fundo distinto daquele praticado nos EUA e África do Sul ('preconceito de marca' ao invés de 'preconceito de origem'), a indicar a inaplicabilidade, aqui, das discussões sobre percentuais de genes africanos, europeus ou indígenas. 11. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Aplicação aos atos de todos os poderes públicos, vinculando legislador, julgador e administrador, mas com extensão e intensidade distintas conforme se trate de atos legislativos, da administração ou da jurisdição. Limites de 'conformação' do administrador e do legislador a reduzir a análise de todas as possibilidades de escolhas postas à disposição. Verificação de: a) adequação, que não constitui o dever de escolher o meio mais intenso, melhor e mais seguro, mas sim a anular o ato somente quando a inadequação for evidente e não for, de qualquer modo, justificável; b) necessidade, em relação ao meio eficaz e menos desvantajoso para os cidadãos; c) proporcionalidade em sentido estrito, comparando a importância da realização do fim e a intensidade da restrição de direitos fundamentais. Metas fixadas para educação nacional pelo Legislativo com duração de dez anos, passíveis de revisão. Não-comprovação de que as premissas para instituição de critérios de 'inclusão social'- ampliação do acesso para estudos de ensino público e autodeclarados negros, promoção da diversidade étnico-racial no ambiente universitário, educação de relações étnico-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *raciais - não são critérios adequados, necessários e proporcionais para os fins constitucionais de repúdio ao racismo, redução das desigualdades sociais, pluralismo de ideias, garantia de padrão de qualidade do ensino, defesa e valorização da memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, valorização da diversidade étnica e cultural e promoção do bem de todos, 'sem preconceitos de raça e cor e quaisquer outras formas de discriminação'. Percentuais de cotas que não constituem patamar elevado, seja porque 87% da oferta de vagas vem do ensino público médio e fundamental, seja porque a população negra brasileira é superior ao percentual estabelecido nas cotas. Reconhecimento de que os programas deixam sempre à disputa livre da maioria 'a maior parcela de vagas', como forma de 'garantia democrática do exercício de liberdade pessoal e realização do princípio da não-discriminação' (Cármen Lucia Antunes)."*

2. O Recorrente alega que o Tribunal *a quo* teria contrariado os arts. 5º, *caput*, 22, inc. XXIV, 37, *caput*, 205 e 208 da Constituição da República, em razão da *"flagrante (...) inconstitucional[idade d]a regra do edital do concurso vestibular de 2008"*, que previu a reserva de cotas para negros egressos de escolas públicas.

Afirma que *"prestou vestibular em janeiro de 2008* [para o curso de Administração oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS e,] *apesar de* [ter sido] *classificado* [em 132º, do total de 160 vagas], *e alcançado a média superior de muitos candidatos egressos de escola pública e autodeclarados negros, não alcançou pontuação suficiente à alcançada por alguns candidatos inscritos e aprovados para vagas ofertadas no percentual reservado aos cotistas"*.

Assevera que a ação afirmativa estabelecida pela Recorrida contraria o princípio da legalidade, ao argumento de que, *"se a Carta Magna diz que não pode haver preconceito, é porque assim deve ser, sem concessões de nenhuma espécie. A primeira medida, portanto, para tornar sem efeito um princípio constitucional estampado claramente no texto da Lei Maior e, desse modo, outorgar legitimidade à ideia das cotas é uma emenda à Constituição, não uma lei*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

ordinária e muito menos, uma inútil Resolução universitária".

Argumenta que a Decisão n. 134/2007 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul contraria o art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República porque *"matérias relativas às diretrizes e bases da educação nacional só podem ser tratadas pela legislação federal"*, de competência privativa da União.

Destaca que a Lei n. 10.558/2002 não instituiu sistema de cotas, pelo que a Recorrente não o poderia ter feito, dada a inexistência de lei complementar exigida pelo parágrafo único do art. 22 da Constituição da República.

O Recorrente assevera que a Recorrida *"desrespeitou a interdição constitucional da discriminação. Em primeiro lugar porque criou distinção arbitrária em favor de concorrentes ao vestibular oriundos do ensino público médio ministrado por estabelecimentos escolares públicos em o fazendo, as normas impugnadas elegeram um discrímen fundado em atributo pessoal (a origem escolar), o que é vedado pela Lei Fundamental. Em segundo lugar, porque discriminam candidatos ao vestibular com base em característica extrínseca dos concorrentes – a cor da pele. Alunos carentes ou pobres que se autodeclaram "negros" levam vantagem sobre os carentes ou pobres "brancos" e "pardos", já que podem ingressar no ensino superior estadual com notas mais baixas do que estes últimos, em virtude de lhes terem sido destinadas vagas específicas e previamente reservadas".*

Alega que, nos termos dos arts. 206, inc. I, e 208, inc. V, da Constituição da República, *"o mérito é a única medida capaz de garantir a igualdade de acesso ao ensino, sobretudo ao ensino superior onde o ingresso se faz por concurso público de provas".*

Por fim, argumenta que, *"considerando que as 44 vagas da administração foram reservadas ao sistema de cotas*[, evidenciados estariam]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

os percentuais de vagas reservados pela legis1ação impugnada não são proporcionais e razoáveis; ao contrário, são excessivos e desarrazoados", daí a inconstitucionalidade da Decisão n. 134/2007 do Conselho Universitário da Recorrida.

Pede o provimento do recurso e a concessão da segurança para *"matricular-se no curso de Administração – noturno da UFRS"*.

3. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS apresentou contrarrazões e argumentou, preliminarmente, *"o descabimento do recurso"*, pois o Recorrente deixou de atacar todos os fundamentos do acórdão recorrido (arts. 3º, inc. III e IV, 4º, inc. VII, 5º, *caput* e inc. XLVII, 206, inc. III e VII, 207, 208, inc. V, 215 e 216 da Constituição da República), a evidenciar a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, asseverou:

a) a validade das ações afirmativas das universidades públicas, por serem "*instrumento de valorização dos princípios democráticos, respeito às diferenças e as diversidades socioeconômica e étnico-social. Corolário lógico dos Princípios Constitucionais da não discriminação e do combate à desigualdade real"*.

b) "o sistema de Ações Afirmativas da UFRGS reserva 30% das vagas em todos os cursos aos alunos oriundos de escolas públicas, sendo que deste percentual, metade é reservada a negros que também tenham cursado pelo menos a metade do ensino fundamental e todo o ensino médio em escola pública".

c) "o estabelecimento de cotas para alunos oriundos de escola pública não fere o principio da isonomia em razão de que é dada a oportunidade para todos estudarem tanto em escola pública quanto em escola privada, sendo a escolha uma opção individual".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

d) a política de ações afirmativas implementada pela reserva de vagas de ingresso oferecidas no concurso vestibular (Decisão 134/2007 – Consun) é resultado de ampla discussão e do exercício da autonomia da universidade, *"garantida na LDB, e seguindo a política de inclusão fomentada pelo MEC (hoje são mais de 50 Instituições Públicas de Ensino Superior que possuem alguma forma de Reserva de Vagas ou Cotas)".*

Requer o acolhimento da preliminar de não conhecimento e, no mérito, pede o não provimento do recurso.

4. Em 17.9.2009, o Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada:

> *"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS ("COTAS"). AÇÕES AFIRMATIVAS. RELEVÂNCIA JURÍDICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL" (DJ 9.10.2009).*

5. Em 5.4.2009, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente Recurso Extraordinário e afirmou que: *a) "o princípio da autonomia universitária (...) deve ser ponderado com os demais princípios*[, destacando a inexistência de] *princípio que restrinja os efeitos da autonomia universitária, do direito à educação, do princípio da isonomia, do princípio da proporcionalidade"*; e *b)* a aplicação do princípio da isonomia pelo acordão recorrido evidencia *"a constitucionalidade do conteúdo do sistema de cotas, a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e de baixa renda, negros ou pardos".*

6. O que se põe em foco no presente recurso extraordinário, em síntese, é saber se: *a)* ao instituir sistema de reserva de cotas (Decisão n. 134/2007), no exercício de sua autonomia administrativa (art. 207 da Constituição), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul teria contrariado o art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República e *b)* o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

sistema de reserva de cotas instituído pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul afrontaria o princípio da isonomia.

Autonomia universitária e a instituição do sistema de reserva de cotas

7. O art. 207 da Constituição da República prevê:

> *"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".*

8. Por força do art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República, a regulamentação da matéria compete à União:

> *"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*
> *(...)*
> *XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;"*

9. Sobre esse conjunto de regras de competência, José Afonso da Silva esclarece:

> *"A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar"* (SILVA,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional positivo*. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 479).

Ao discorrer sobre a competência privativa da União, Raul Machado Horta assevera que:

> *"a competência legislativa incorpora os preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal, através da lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de manifestação da vontade legislativa. Daí a correspondência entre as atribuições de competência geral e as da competência de legislação, sem a qual a competência geral permaneceria um corpo inerme, sem ação e sem vontade. A correspondência entre as duas competências às vezes se exterioriza na coincidência vocabular das expressões, como se dá na repetição de atribuições (...), com idênticas palavras ou com expressões equivalentes, e quando a correspondência não se exteriorizar de forma ostensiva irá ela alojar-se no inciso mais genérico da competência legislativa federal, abrigando-se no amplo conteúdo do direito material e do direito processual (art. 22, I), que poderá absorver na legislação codificada ou não codificada as atribuições da Federação, situadas na competência geral do Estado soberano"* (HORTA, Raul Machado. *Direito Constitucional*. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 351).

10. No exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República, a União aprovou a Lei n. 9.394/1996, que, em seu art. 53, estabelece:

> *"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:*
>
> *I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;*
>
> *II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;*
>
> *IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;*
>
> *V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;*
>
> *VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;*
>
> *VII - firmar contratos, acordos e convênios;*
>
> *VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;*
>
> *IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;*
>
> *X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.*
>
> *Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:*
>
> *I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;*
>
> *II - ampliação e diminuição de vagas;*
>
> *III - elaboração da programação dos cursos;*
>
> *IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;*
>
> *V - contratação e dispensa de professores;*
>
> *VI - planos de carreira docente".*

11. Diferente que sustentado pelo Recorrente, não se há cogitar de a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao instituir sistema de reserva de cotas (Decisão n. 134/2007), ter usurpado competência da União prevista no art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República.

12. A União exerceu a competência que lhe foi outorgada pelo art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República, ao aprovar a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, um conjunto de *"normas gerais subordinadas aos demais princípios constitucionais"* (SILVA, Ives Gandra Martins. Comentários à Constituição do Brasil. 2.ed. 3º.v,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

tomo I, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 376).

E, nas palavras de J. J. Gomes Canotilho, adotou o modelo para, entre outros objetivos, concretizar a autonomia universitária estatuída no art. 207 da Constituição da República (Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Almedina: Coimbra, 2006).

Em suas contrarrazões, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul defendeu a sua autonomia, destacando a existência de

> *"consenso sobre a ampla margem de atuação deferida pela Constituição de 1988 às instituições de ensino superior. (...) O alvitre doutrinário inclusive já recebeu agasalho jurisprudencial, o que dá conta o Recurso Especial n. 546.232/RS em que foi Relatora a Ministra Eliana Calmon, quando se firmou que o acesso às universidades não se baliza estritamente pelo critério meritocrático, aferido pelo exame vestibular, podendo ser definido conforme o princípio da autonomia didático-científica das universidades, mediante articulações destas com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Sob o aspecto formal, portanto, não há reparos possíveis à constitucionalidade do programa de cotas da UFRGS, porque alicerçada em norma constitucional que lhe confere a necessária competência (art. 207). Nessa toada, aliás, Samuel Rodrigues Barbosa (Autonomia Universitária Investigações dogmáticas sobre a constitucionalização de um principio, in Direito Constitucional, Estudos em homenagem a Paulo Bonavides, 2003, p.64), remetendo à lição de Botelho de Mesquita sobre a autonomia universitária (em parecer inédito), conclui que "todo poder é limitado por seus fins". Assim, caso haja ''pluralidade de poderes normativos em relação a um mesmo fim", ou seja, pluralidade de fontes de Direito, a harmonização dessas fontes potencialmente em conflito será dada pela própria norma que as cria, ou seja, pela própria a Constituição Federal de 1988: "é, pois, na constituição que se devem procurar os limites da autonomia universitária". Posto de outra forma, o que importa de fato é a constitucionalidade material da norma universitária, porque sob o aspecto formal a autonomia universitária está devida e*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *constitucionalmente consagrada. Importa, dessarte, saber-se se o exercício dessa autonomia está dentro das balizas materiais da CF/88 (cf. ADI-MC 1588, DJ 18/6/01)"* (grifos nossos).

Nesse ponto cumpre esclarecer que o rol de atribuições densificadoras da autonomia das universidades não é taxativo. Ao se valer, no *caput* do art. 53 da Lei n. 9.394/1006, da expressão *"sem prejuízo de outras"* atribuições, o legislador ordinário autorizou as universidades, nos limites das normas constitucionais e da legislação ordinária delas decorrente, a criarem programas favoráveis ao cumprimento de sua função social, entre as quais se pode incluir a instituição de sistema de reserva de cotas.

Para afastar esse argumento do Recorrente, a Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria fez constar do acórdão recorrido:

> *"Sustenta-se, também, que as políticas afirmativas não encontram respaldo na autonomia universitária. A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que é possível, como decorrência da autonomia universitária, prevista no art. 207, V, da Constituição, o estabelecimento de sistema de cotas. Ainda que autonomia não se confunda com soberania, é fato que a previsão se encontra consentânea com a legislação infraconstitucional e constitucional. Não é demais lembrar que a LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelece, em seu art. 53, que a autonomia tem como parâmetros "as normas gerais da União" e do "respectivo sistema de ensino" (inciso I) ou mesmo "fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio" (inciso IV), sendo certo que cabe aos colegiados de ensino decidir sobre "ampliação e diminuição de vagas" (art. 53, §único, II). Relembre-se que, recentemente, a PUC/RS reduziu o número de vagas para residência médica, o que incorreu em protestos da AMRIGS, sem que isto tenha gerado, até o presente momento, qualquer contestação judicial, conforme se verifica do site da associação (www.amrigs.com.br). Ora, podendo reduzir ou mesmo*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *ampliar as vagas, "dentro dos recursos orçamentários disponíveis" não há impedimento legal para o exercício da autonomia no tocante à fixação de cotas. Ademais, cabe à União, constitucionalmente, o financiamento das instituições públicas e o exercício, "em matéria educacional, de função redistributiva e supletiva" (art. 211, §1º, CF)".*

Em estudo intitulado *"Universidade federativa autônoma e comunitária"*, Geraldo Moisés Martins salienta:

> *"O que nos parece importante ressaltar dessas perspectivas, é que a autonomia prevista pelo artigo 207 da Constituição é inerente à configuração da universidade, mas não significa independência absoluta. Considerando que ela faz parte de um contexto social, que integra a comunidade e é constituída pelos seus membros, a sua existência e funcionamento têm vínculos estreitos com essa comunidade. Daí, porque, com se examinará adiante, a gestão federativa e autônoma, implica, também, uma gestão comunitária.*
>
> *Seria, entretanto, improcedente pretender, aqui, qualificar, identificar ou estabelecer parâmetros definidores para o exercício da autonomia. Trata-se de matéria do arbítrio exclusivo da própria universidade, ou seja, está justamente aí a prerrogativa principal da sua autonomia. Assim, ao estabelecer seus rumos, projetos e compromissos, ela própria estará definindo as suas relações de dependência e os seus condicionamentos.*
>
> *O exercício da autonomia didática, por exemplo, deriva da sua capacidade de conduzir, sem restrições, o processo e as atividades de ensino e aprendizagem. Na universidade federativa e autônoma, essa capacidade é garantida pelas próprias competências organizacionais e gerenciais, ou seja, pelos esforços dos parceiros federativos com a participação da comunidade que ensina e aprende. A autonomia de ensinar e aprender não é garantida pela aprovação e certificação formal e burocrática de estatutos, de programas, de títulos etc. Não é ditada por instâncias de um ministério ou de conselhos e secretarias estaduais de educação.*
>
> *A autonomia científica, por sua vez, corresponde à efetiva*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *capacidade para desenvolver e empregar técnicas e metodologias que permitam a produção do conhecimento, o domínio das ciências, o aproveitamento e a elaboração dos saberes pertinentes à realidade.*
>
> *Autonomia administrativa é a exercida, no âmbito acadêmico, pela capacidade de determinar políticas de ensino, pesquisa e extensão, dentro das garantias da "livre manifestação do pensamento" e da "livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença" (Incisos V e IX do artigo 5° da Constituição), o que implica, no âmbito gerencial, a autonomia para mobilizar e empregar, da forma mais apropriada, os meios, os recursos organizacionais, financeiros e patrimoniais ao alcance dos seus objetivos.*
>
> *Portanto, no modelo da universidade federativa, não há sentido em estabelecer delimitações para o exercício da autonomia, fora do que está consagrado pela Carta Constitucional"* (MARTINS, Geraldo Moisés. Universidade federativa autônoma e comunitária. Brasília: Athalaia Editora, 2008. p. 216-217, grifos nossos).

Na mesma linha são as lições de Ives Gandra da Silva Martins: "*não há condicionamento a esta autonomia, nem pode haver restrição legal a turvar a eficácia dessa autonomia. Se a lei ordinária ou complementar pretender reduzir a ampla autonomia que a Constituição assegura, será uma lei complementar ou ordinária inconstitucional. É interessante que o art. 207 não condiciona a autonomia aos termos da lei, mas apenas declara que as Universidades e os institutos de pesquisas são autônomos e, neste particular, a lei não pode reduzi-la"* (Consulta juntada na ADI 3.330/ DF, grifos nossos).

Também Anna Cândida da Cunha Ferraz salienta que

> *"a inserção constitucional da autonomia universitária na obra do constituinte originário traz como consequência a sua intangibilidade por normas de hierarquia inferior: leis federais, leis estaduais e municipais, ou mesmo as Constituições dos Estados (ainda que obras de um poder constituinte estadual autônomo por força do princípio federativo que preside a organização do Estado no Brasil).*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *Inscrito na Constituição Federal, o princípio da autonomia universitária tem uma dimensão fundamentadora, integrativa, diretiva e limitativa própria, o que significa dizer que é na própria Constituição Federal: a) que se radica o fundamento do instituto; b) que é dela que se extrai sua força integrativa em todo o sistema federativo do País; c) que a Constituição Federal preordena a interpretação que se possa dar ao instituto; d) que os limites que se podem opor à autonomia universitária têm como sede única a própria Constituição Federal; e) que o princípio da autonomia universitária, como princípio constitucional, deve ser interpretado em harmonia – mas no mesmo nível – com os demais princípios constitucionais"* (FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. *A autonomia universitária na constituição de 05.10.1988*. Rio de Janeiro, São Paulo, Revista de direito administrativo, n. 215, p. 117-142, jan./mar. 1999. p. 123).

Também tive a oportunidade de manifestar-me sobre a questão da autonomia das universidades em consulta que me foi formulada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – Confenen, juntada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.330:

> *"Note-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi elaborada em atendimento ao previsto na Seção I, do Tít. VIII, da Constituição da República. Ela dá efetividade e consistência aos princípios elencados na Lei Fundamental para a educação nacional. (...)*
>
> *A questão central a ser enfrentada para o atendimento da igualdade constitucional é como se estabelecem os critérios de desigualação, os quais não podem decorrer de preconceito nem gerar maior desigualdade, pois em qualquer dos casos o que se teria seria a afronta ao princípio e não o seu acatamento.*
>
> *De se entender, pois, que a igualação faz-se juridicamente segundo o que se positiva no sistema de direito. O critério para que se considerem iguais ou desiguais as pessoas haverá que ser fixada pelo legislador. Este tem de se ater a fator de discrímen que se compatibilize com os princípios constitucionais e que não supere as vedações constitucionais (discriminação em razão de sexo, raça, crença, etc.).*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

Qualquer desigualação que estranhe aos parâmetros constitucionalmente definidos é considerado exacerbação indébita do legislador e não pode ser validada no sistema. (...)

É bem certo que não se está a se referir à uniformidade do tratamento a ser garantido aos cidadãos, mas, na fórmula antes observada e que comparece como conteúdo do princípio da igualdade na fase atual do constitucionalismo, a desigualação somente pode ser tida como válida juridicamente se definida em função de critérios objetivos e legítimos.

A norma contida no sistema constitucional inaugurado em 1988 é, pois, fruto amadurecido de uma concepção que se impõe por inegável luta em prol da cidadania, a fim de que as concepções pluralistas e democráticas se possam impor no ensino superior e as entidades possam prestar este serviço segundo idênticos fundamentos nacionais, mas com a garantia da liberdade e do acatamento ao princípio democrático do pluralismo.

O acolhimento daquele princípio constitucional no sistema vigente não se impõe a restrições nem depende de regulamentação. Impõe-se por si e determina o paradigma do ensino universitário a ser observado pelo legislador, que não pode, ainda uma vez, em nossa história, minguar por determinantes legais o que a Constituição assegura como princípio do modelo. A autonomia universitária é direito constitucional titularizado não apenas pelos instituidores ou dirigentes das instituições, mas pelos cidadãos brasileiros, especialmente pelos que a elas acorrem na condição de alunos, mas não apenas estes, pois os estudantes de agora serão os graduados profissionais com os quais a sociedade contará amanhã e para o que ela investe, não apenas com recursos, mas, principalmente, com as suas esperanças.

Com a definição do princípio da autonomia universitária como elemento do sistema educacional afirmado na Lei Fundamental da República firma-se a natureza das instituições de ensino superior. É ela corolário da liberdade de aprender e de ensinar, de pesquisar e de divulgar o resultado do conhecimento científico, de capacitar-se para criar o saber e divulgá-lo em benefício da humanidade.

O acolhimento daquele princípio conjuga-se, assim, com o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *princípio democrático da liberdade individual e da liberdade institucional, por isto é que o art. 209 expressa que 'o ensino é livre à iniciativa privada...'.*
>
> *O princípio da autonomia universitária desdobra-se em seus aspectos didático-científico, administrativo e patrimonial-financeiro. A garantia do respeito à autonomia universitária é bem expressa por Marilena Chauí, ao afirmar que não se deve "sacralizar nem satanizar os interesses das corporações empresariais, nem das corporações universitárias, mas de indagar se a discussão sobre a universidade pública democrática deve ser feita no campo dos interesses ou no dos direitos. Se no de interesses é preciso provar que uns são mais legítimos que outros; se no dos direitos, então, a autonomia universitária é pré-condição para definir campos de interesses" (CHAUÍ, Marilena – Em torno da universidade da resultados e de serviços. Sã/ Paulo: Revista da USP, São Paulo, n. 25, mar./maio, de 1996, p.61).*
>
> *Não pode, pois, a lei impor restrições àquele princípio, sob pena de burla constitucional que torna inválida a norma elaborada. E assim é porque a Constituição apenas estabelece a obrigação universitária de as instituições de ensino darem cumprimento às normas gerais da educação nacional e à autorização e avaliação de sua qualidade pelo Poder Público.*
>
> *Qualquer outro imposição que não caiba nos ditames afirmados nos incisos do art. 209 da Constituição da República não se comporta nos limites nela fixados e não são tidos como válidos no sistema jurídico vigente"* (grifos nossos).

Em síntese, tem-se que, se, por um lado, o constituinte originário foi enfático ao atribuir autonomia à universidade (art. 207 Constituição da República) e afirmar que "*a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho*" (art. 205 da Constituição da República), por outro e de forma consentânea com os desígnios constitucionais, o legislador ordinário valeu-se da expressão "*sem prejuízo de outras*" (*caput* do art. 53 da Lei n. 9.394/1996) para autorizar a atuação das universidades

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

na consecução de seus objetivos, que são também aqueles do Estado brasileiro (art. 3º da Constituição da República)..

13. De se acentuar, também, ao contrário do que sustentado no presente recurso extraordinário, que a ausência de previsão expressa de sistema de reserva de cotas na Lei n. 10.558/2002 não importa em vedação ao exercício da autonomia assegurada à Universidade, até mesmo para acolher o modelo.

Aquela lei criou o *"Programa Diversidade na Universidade"* e, a despeito de não prever taxativamente os critérios a serem adotados nos aludidos sistemas de cotas, tornou evidente o compromisso novamente firmado pelo Estado brasileiro de *"implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente aos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros"* (art. 1º).

Luiz Fernando Martins da Silva lembra que, no Brasil, "*o pioneirismo da criação de políticas de ação afirmativa no âmbito da educação pública superior (...) coube ao Governo Federal, em 1968, com a Lei n. 5.465/68 ('Lei do Boi)", que previa em seu art. 1º a reserva de vagas, por meio de cotas, nos seguintes termos: "os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, de preferência, 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam estabelecimentos de ensino médio"* (SILVA, Luiz Fernando Martins da. Políticas públicas de ação afirmativa e seus mecanismos para a população negra no Brasil: perspectivas atuais. Disponível em: http://www3.tst.jus.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/revistadotst/Rev_76/Rev_76_3/art4_augustocesar.pdf. Consulta em 23.4.2012).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

Como pontuado pela Desembargadora Lúcia Maria Luz Leiria no voto condutor do acórdão recorrido, não é por falta de instrumentos normativos que a universidade permanecerá inerte. Entre os fundamentos adotados em seu voto para divergir, no que foi acompanhada pelos demais pares, asseverou:

> *"A alegação de que não existe base legal, no ordenamento pátrio, é equivocada. É que desde o Primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado no governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do Decreto nº 1.904/1996, a questão das políticas afirmativas já estava incluída, restando, reafirmada pelo governo brasileiro, quando participou da Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban (31-08 a 08-09-2001). A Declaração de Durban, de 2001, da qual o Brasil foi um dos signatários, reconheceu, no texto final (disponível no site http://www.mulheresnegras.org/doc/Declafinal.pdf) que o combate ao racismo é "responsabilidade primordial dos Estados" (parágrafo 99), instando os governos a adotar inclusive "programas de ações afirmativas ou medidas de ação positivas, para promoverem o acesso de indivíduos que são ou podem ser vir a ser vítimas de discriminação racial nos serviços sociais básicos,incluindo ensino fundamental" (parágrafo 100) e tomar medidas que capacitem estudantes "independente de raça, cor, descendência, origem étnica ou nacional" a freqüentarem "instituições de ensino superior" (parágrafo 123, item "g"), além de assegurar ambiente escolar seguro e livre de racismo (parágrafo 123, item "f"). Esta endossou, nos parágrafos 107 e 108, a importância de os Estados adotarem ações afirmativas para aqueles que foram vítimas de discriminação racial, xenofobia e outras formas de intolerância correlata.*
>
> *Não sendo nova, pois, a questão, ela se encontra internamente incorporada no ordenamento jurídico brasileiro, desde que o Decreto nº 65.810, de 08-12-1969, internalizou a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que previu, no art. 1º, parágrafo 4º, a adoção de "discriminação positiva", no sentido de que medidas especiais sejam "tomadas com o objetivo precípuo de assegurar, de forma conveniente, o progresso de certos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

grupos sociais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em igualdade de condições, não serão consideradas medidas de discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido atingidos os seus objetivos".

O marco normativo, pois, do conceito de "discriminação" está balizado pelos parâmetros fixados naquela Convenção Internacional. (...)

Ao contrário, pois, do alegado, o Brasil poderia responder, no plano internacional, justamente por não estabelecer, na prática, a realização de "ações afirmativas" com as quais já se comprometera mais de trinta anos, ainda mais quando, desde o Decreto nº 4.738, de 12-06-2003, em seu art. 1º, reconheceu a competência do "Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de violação dos direitos humanos" conforme previsto no art. 14 da Convenção Internacional supracitada.

Com mais razão, ainda, quando, como no caso da UFRGS e da UFPR, bem como de várias outras universidades, fica estabelecida duração e verificação periódica dos resultados na aplicação do sistema de cotas. Não se estabeleceu, pois, uma regra a vigorar indefinidamente, sem qualquer análise de sua eficácia.

O Congresso Nacional discutiu e aprovou o projeto que resultou na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001- sancionada, portanto, pelo Presidente da República, que instituindo o Plano Nacional de Educação, com duração de dez anos (art. 1º) e avaliações periódicas, a partir do quarto ano, com "vistas à correção de deficiências e distorções" (art. 3º, § 2º), inseriu, entre seus objetivos e metas (item 4.3 do referido plano), "criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação superior, através de programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições nos processos de seleção e admissão a esse nível de ensino". Metas, pois, estabelecidas, inicialmente, para um período de dez anos.

Relembro, ainda, que o Presidente da República editou a MP nº 63/2002 que, submetida à apreciação do Congresso Nacional, foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

transformada na Lei nº 10.558, de 13-11-2002, estabelecendo o "Programa Diversidade na Universidade", com a finalidade de "implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente aos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros" (art. 1º). Trata-se, pois, de um programa fomentado pelo Ministério da Educação, com transferência de recursos a entidades de direito público ou privado (art. 2º). Ademais, o Congresso Nacional aprovou o projeto de conversão em lei da MP nº 111/2003, que criou a "Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial" (Lei nº 10.678/2003) para "formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância" (art. 2º da Lei nº 10.678/2003).

Não é possível, pois, que o Executivo esteja autorizado a "implementar" as políticas, com anuência do Poder Legislativo, e se entenda a falta de base legal para qualquer aplicação de política afirmativa.

Ademais, o Decreto nº 4.228, de 13-05-2002, instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas, para promover "os princípios da diversidade e pluralismo no preenchimento de cargos da administração e na contratação de serviços por órgãos do governo", prevendo metas percentuais de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, já em 2001, por meio das Portarias nº 202 e 224, lançara programa semelhante, para os cargos comissionados, destinando 20% das vagas para negros, 20% para mulheres e 5% para portadores de necessidades especiais, no que foi seguido pelo Ministério da Justiça, por meio da Portaria nº 1.156/2001, e pelo Ministério da Cultura, por meio da Portaria nº 484, de 22-08-2002. O STF também, pioneiramente, em 2001, estabelecera critérios de ações afirmativas para contratação para prestação de serviços na área de jornalismo, estabelecendo a obrigação da contratada de "recrutar e selecionar os profissionais que serão alocados para a prestação de serviços, encaminhando-os para avaliação do contratante, se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

necessário, observado o limite mínimo de 20% para negros e negras"; e o Instituto Rio Branco destina bolsas de estudo para afrodescendentes em cursos preparatórios para a carreira de diplomata. (...) O conceito de discriminação encontra respaldo no art. 1º, I, da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, internalizada na ordem nacional, com a seguinte redação: 'Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública'.

Em sentido similar, a previsão do art. 1º da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, originalmente internalizada com ressalvas pelo Decreto nº 86.460/84 e hoje integralmente aderido na ordem interna pelo Decreto nº 4.377/2002:

'Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.'

Desde o início, pois, os tratados internacionais não incluem no conceito de discriminação as hipóteses de diferenciação legítima, decorrentes da elaboração e aplicação de normas jurídicas em face de situações desiguais, tais como as qualificações exigidas para determinados empregos (vide o art. 1º seção 2 da convenção sobre discriminação em emprego e profissão, Convenção nº 111-OIT, internalizada pelo Decreto 62.150, de 19-01-1968).

Neste sentido, o constitucionalista Laurence Tribe (American Constitutional Law. 2ªed. New York, Foundation Press, 1988, p. 1516) destaca que o objetivo da "equal protection clause" não é "acabar com pensamentos impuros, mas garantir uma medida de dignidade humana a todos. A Constituição pode ser ofendida não só por atos individuais de discriminação racial, mas também por regras,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *políticas e práticas governamentais que, de forma perene, reforcem o status subordinado de qualquer grupo"* (grifos nossos).

14. Acrescente-se a circunstância de a atuação das universidades não estar condicionada à aprovação de lei complementar prevista no parágrafo único do art. 22 da Constituição da República.

Dispõe o parágrafo único do art. 22 da Constituição da República que a competência privativa da União para legislar sobre *"as diretrizes e bases da educação nacional"* pode ser exercida por Estado-membro se houver lei complementar da União que autorize.

Sobre as assertivas do Recorrente quanto ao ponto há de se anotarem dois pontos.

Em primeiro lugar não se mostra possível equiparar as universidades aos Estados para fins de delegação de competência legislativa prevista no art. 22 da Constituição.

Em segundo, tem-se que a Lei n. 9.394/1996, lei geral regulamentadora das diretrizes e bases da educação nacional, esgotou, em princípio, a matéria e conferiu às universidades, seguindo os limites constitucionais e aqueles previstos nos arts. 51 e 53 da aludida lei, atuar com vistas à consecução de sua responsabilidade social.

Aquela Lei, interpretada à luz da Constituição da República, permitiu que as universidades, por meio de ações afirmativas, adotassem mecanismos aptos à promoção da diversidade étnico-racial, cujo desdobramento esperado é o acréscimo cultural à vida acadêmica e a supressão de preconceitos e estereótipos raciais e sociais.

15. Como leciona Boaventura de Sousa Santos:

> *"A responsabilidade social da universidade tem de ser assumida*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *pela universidade, aceitando ser permeável às demandas sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais que não tem poder para as impor. A autonomia universitária e a liberdade acadêmicas – que, no passado, foram esgrimidas para desresponsabilizar socialmente a universidade – assume agora uma nova premência, uma vez que só elas podem garantir uma resposta empenhada e criativa aos desafios da responsabilidade social. Porque a sociedade não é uma abstracção, esses desafios são contextuais em função da região, ou do local e, portanto, não podem ser enfrentados com medidas gerais e rígidas. A discriminação racial ou étnica ocorre em conjunção com a discriminação de classe, mas não pode ser reduzida a esta e deve ser objeto de medidas específicas"* (SANTOS, Boaventura de Sousa. *A Universidade no século XXI*: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez, 2004. p. 91, grifos nossos).

O reconhecimento de que *"a discriminação racial ou étnica ocorre em conjunção com a discriminação de classe, mas não pode ser reduzida a esta e deve ser objeto de medidas específicas"* (SANTOS, Boaventura de Sousa. *A Universidade no século XXI*: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez, 2004. p. 69), evidencia a necessidade de se levar em conta a sociedade a qual se insere a universidade.

Essas peculiaridades, como destacado no voto da Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, justificam a circunstância de inexistir *"um sistema único de ações afirmativas implantado nas universidades, destoando os critérios nas 20 universidades federais e 19 estaduais que adotaram tal política. A título de exemplo, a UFBA fixou, desde 2002, 43% para egressos do ensino médio da rede pública, sendo destas 85% para pardos e negros. A UNEB, por sua vez, 40% para afrodescendentes. A UNICAMP fixou pontuação extra para egressos de ensino público (30 pontos), além de pontos para negros (10 pontos). Isto tudo a indicar, pois, a plena autonomia universitária, e a impossibilidade de estabelecimento de um modelo único, em desacordo com as situações histórico-culturais de cada universidade ou região do país. Todas elas fixadas como*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

políticas temporárias e sujeitas a reavaliação periódica dos seus efeitos" (acórdão recorrido).

16. A solução da questão central posta em julgamento forjou-se para propiciar ensino básico democratizado e de qualidade para todos, o que conduz à conclusão de que a instituição de sistemas de reservas de cotas raciais pelas universidades não constitui a única providência necessária para o mister complexo e dinâmico de construir de maneira equilibrada a sociedade pluralista e democrática.

Nesse contexto, dar cumprimento ao comando constitucional segundo o qual *"as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata"* (art. 5º, § 1º, Constituição da República) significa, no mínimo, reconhecer que cabe a todos e a cada um dos atores sociais atuação voltada à construção e reconstrução de sociedade na qual todos possam igualmente adquirir ou ter oportunidade de vir a dotar-se de igual capacidade intelectual, elemento conformador do princípio da dignidade da vida, a qual não pode conviver com a perenização das desigualdades.

17. Em 13.11.2007, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 26.071/DF, Relator Ministro Ayres Britto, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu:

> *"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. § 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 8.112/90. LEI Nº 7.853/89. DECRETOS NºS 3.298/99 E 5.296/2004. (...) 3. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> *1988. 4. Recurso ordinário provido*" (DJ 1º.2.2008, grifos nossos).

Em seu voto, o Ministro Ayres Britto asseverou:

> *"Nesse rumo de ideias, nunca é demasiado lembrar que o preâmbulo da Constituição de 1988 erige a igualdade e a justiça, entre outros, "como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos". Sendo certo que reparar ou compensar os fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica é política de ação afirmativa que se inscreve, justamente, nos quadros da sociedade fraterna que a nossa Carta Republicada idealiza a partir das suas disposições preambulares"* (DJ 1º.2.2008).

18. No caso vertente, a própria Universidade, ciente de sua responsabilidade social e da autonomia que lhe foi assegurada pelo art. 207 da Constituição da República de 1988 e regulamentada pelo art. 53 da Lei n. 9.394/1996, estabeleceu critérios garantidores da densificação dos objetivos previstos no art. 3º da Constituição. Como venho destacando desde a década de 90 do século passado:

> *"Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa – construir, erradicar, reduzir, promover* [contidas no art. 3º da Constituição da República] – *são de ação, vale dizer, designam um comportamento ativo. O que se tem, pois, é que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são definidos em termos de obrigações transformadoras do quadro social e político retratado pelo constituinte quando da elaboração do texto constitucional. E todos os objetivos contidos, especialmente, nos três incisos acima transcritos do art. 3º da Lei Fundamental da República traduzem exatamente mudança para se chegar à igualdade. Em outro dizer, a expressão normativa constitucional significa que a Constituição determina uma mudança do que se tem em termos de condições sociais, políticas, econômicas e regionais exatamente para se alcançar a realização do valor supremo a fundamentar o Estado Democrático de Direito constituído. Ação afirmativa: o conteúdo jurídico do princípio da igualdade"* (ROCHA, Cármen Lúcia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

> Antunes. Ação Afirmativa: O conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Revista de Informação Legislativa, v. 33, n. 131, p. 283-295, jul./set. 1996).

19. Como esclarecido na sentença e confirmado pelo Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz no acórdão recorrido:

> *"Conforme o Boletim de Desempenho do impetrante (fl. 44), verifica-se que o estudante obteve média de 566,44 pontos, e ficou na 132ª posição na classificação geral do curso de Administração - Noturno. Inscrito no sistema de ingresso universal, para o qual oferecidas 112 vagas, de um total de 160 vagas existentes, o impetrante não foi aprovado (fl. 44). De sua vez, o Quadro de Lotação dos Candidatos em 1ª Opção (fls. 46-50) revela que o primeiro colocado aprovado pelo acesso universal obteve 694,86 pontos, e o último, 573,70; o primeiro aprovado para as vagas destinadas aos egressos do ensino público (cotas exclusivamente sociais) obteve 573,51 pontos, e o último, 525,05; o primeiro aprovado para as cadeiras destinadas aos egressos do ensino público e autodeclarados negros (cotas raciais) obteve 527,26, e o último, 463,61 pontos".*

Não há plausibilidade jurídica relevante na argumentação a comprometer a validade do edital ou da conclusão adotada pela Universidade.

O Recorrente, candidato a uma das vagas oferecidas pelo acesso universal, não alega qualquer desconhecimento das regras previstas no edital do certame, segundo o qual 30% do total das vagas existentes foram reservados *"para candidatos optantes egressos do ensino público"* (item 1.5.4 do edital), sendo, entre essas vagas, metade delas *"garantida aos candidatos que se autodeclararem negros no ato da inscrição"* (item 1.5.5).

Pela via do mandado de segurança, o Recorrente tentou demonstrar, sem sucesso, que os 566,44 pontos por ele alcançados seriam suficientes para sua aprovação no vestibular de 2008 para o Curso de Administração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

Noturno. É que "*o primeiro colocado aprovado pelo acesso universal obteve 694,86 pontos, e o último, 573,70*".

20. Ainda que assim não fosse, a pretensão do Recorrente não poderia ser atendida. Como ressaltado pela Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria no acórdão recorrido, *"se a previsão de cotas fosse inconstitucional, conforme alegado, seria a sua previsão editalícia e não a sua aplicação na prática que geraria a impetração do mandado de segurança. Ou seja, a alegação de inconstitucionalidade total da previsão editalícia teria o condão de fulminar a própria pretensão da parte, pela decadência de sua impetração, contrariamente, pois, aos seus interesses"*.

21. Inexistindo dúvidas quanto à possibilidade de, no exercício de sua autonomia universitária, as universidades instituírem validamente sistemas de cotas no processo seletivo de ingresso de discentes, o que se exige é a fixação de critérios objetivos (como amplamente analisado na ADPF 186), de modo que o candidato possa se adequar da forma mais justa e ampla às condições do concurso vestibular.

22. O estabelecimento do sistema de reserva de cotas, tal como se deu no caso vertente, assegurou a aplicação dos princípios constitucionais da autonomia universitária, da igualdade, da publicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, devendo, portanto, ser reconhecida a validade da Decisão n. 134/2007 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos atos que foram praticados nos limites de seus termos.

23. Reconhecida a validade dos critérios adotados nas ações afirmativas de cotas raciais para ingresso nas universidades públicas brasileiras, nos termos amplamente debatidos na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.330/DF, há ser mantido o acórdão recorrido.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

24. Pelo exposto, **voto no sentido de negar provimento ao presente recurso extraordinário.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4903424.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285
ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Senhor Presidente, também, a exemplo do que fiz na ADPF nº 186, acompanho o Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3411435.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente eu também acompanho o Relator, como já fizera em relação à ADPF referida, mas também vou me permitir fazer algumas considerações. Tal como no debate que tivemos a propósito do tema do ProUni, a questão aqui é da universidade pública e ela merece algumas considerações. Nesse quadro de desigualdade que se aponta, Presidente, talvez a universidade pública seja um destacado exemplo de desigualdade, porque nós cultivamos um modelo elitista de ensino na universidade pública. Tanto é que, passados todos esse séculos, nós temos uma população de 1,8 milhões de estudantes na universidade pública. Enquanto só aquele programa, o ProUni, …

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Um milhão e quarenta e três mil em seis.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Portanto, em pouco tempo, nós teremos mais pessoas beneficiadas nesse sistema do que na escola pública. E por quê? Por ser um modelo obviamente concebido de forma elitista. Quem já participou de colegiado nas universidades públicas sabe que nenhum professor está disposto a dar aula para mais de trinta alunos, quando o faz. Nós sabemos que, no exterior, há professores dando aulas para oitocentas pessoas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Gilmar, apenas uma observação, pelo menos para darmos a nossa experiência própria. As salas de aula da universidade que eu tive experiência direta - e o apelido era interessante, porque eles denominavam de Rio-Bahia, de tão grande que era, porque tinham cento e cinquenta alunos - elas eram preenchidas - e o Ministro Joaquim Barbosa está aqui presente, foi meu colega de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3152457.

congregação, pode afiançar - com oitenta, cem alunos normalmente.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (RELATOR) - É pouco, muito pouco.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência me permite também, como professor de uma universidade pública, a remuneração é completamente distinta. Acabo de vir do exterior, fui a duas renomadíssimas universidades, não há termos de comparação no que diz de respeito aos vencimentos dos professores universitários em outros países adiantados e os nossos. Há uma grande diferença, para todos nós, dar aula para trinta alunos, para cem, cento e cinquenta, sobretudo quando se trata de corrigir provas.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Neste caso específico, essa discussão é importante, porque, se tivéssemos um pouco mais de vagas num curso de Administração, esse debate não se estaria colocando nessa linha de uma discriminação reversa. Esse é um ponto importante, especialmente num curso em que não temos a necessidade, a imperiosidade de um modelo *numerus clausus*. É evidente que essa questão que Vossa Excelência aponta é muito séria, mas, a rigor, há um problema de estrutura administrativa. Se nós olharmos, por exemplo, a estrutura toda do modelo europeu universitário, ela não se vale apenas do professor, mas também do assistente, do assistente voluntário, dos doutorandos que trabalham nos diversos institutos e que, sem remuneração, acabam exercendo atividades acadêmicas relevantes, mais acessórias. Por exemplo, a atividade de correção de provas e tudo o mais. Então, nós acabamos tendo um grave problema aqui. Tanto é que brinco na Universidade de Brasília, dizendo que a primeira reforma na universidade que tinha que se fazer era uma reforma arquitetônica, uma derrubada de paredes, para que, em vez de trinta, colocassem sessenta ou oitenta pessoas numa sala de aula. Então, aqui está um dos graves problemas desse modelo. Neste caso específico, isso está evidente.

No caso, chamo atenção para um outro aspecto relevante, que já foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3152457.

destacado a partir do cuidadoso voto de Vossa Excelência e também do debate ocorrido no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que é a questão da escola pública. De fato, se formos olhar, talvez, o retrato geral do Brasil, vamos verificar que esse é quase um critério de caráter social, porque, em princípio, estão nas escolas públicas, as escolas dos cursos chamados médios, segundo grau, as pessoas de menor poder aquisitivo. Tanto é que o Jornal Valor, há duas semanas, se não me engano, numa sexta-feira, registrava um estranhíssimo movimento - aquela coisa que só ocorre no Brasil –, que, nos últimos tempos, em função desse acesso das chamadas classes "C", "D" e "E", um milhão de estudantes migraram, supostamente, da escola pública para a escola privada, no segundo grau. Significa dizer que, para essas famílias que vão tendo rendas mais elevadas, elas passam a preferir a escola privada, o que é um sinal preocupante.

Agora, aqui, especificamente no debate do Rio Grande do Sul – e isso foi destacado da tribuna – , o que se mostra? É que há, em razão das peculiaridades – peculiaridades positivas do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma unidade singular no Brasil, tem excelências que devem ser destacadas a partir da própria concepção federativa da autonomia que marca essa noção clara do gaúcho em relação ao próprio sistema federativo, à Federação, a discussão sobre os Colégios de Aplicação, as escolas ou Colégios Militares. Aqui, de fato, pode estar ocorrendo uma discriminação em reverso, porque, obviamente – e nós sabemos bem como são disputados os vestibulares para essas escolas militares – o elemento fático é extremamente importante.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Sim.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Só mesmo no Brasil pode acontecer uma coisa dessas. Uma das maiores violências que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3152457.

se comete neste País é a de submeter crianças de cinco, seis anos de idade a uma espécie de vestibular. Para quê? Para ingresso nessas Escolas de Aplicação das próprias universidades.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Colégios de Aplicação.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Ou seja, é um preâmbulo à discriminação. Famílias de posses podem dar um treinamento especial aos seus filhos de cinco, seis, sete anos de idade para que eles possam ingressar nessas escolas. O corte já começa ali, porque essas escolas são equiparáveis às melhores escolas de primeiro e segundo grau; esses Colégios de Aplicação que existem no Rio de Janeiro, São Paulo e em várias outras cidades - Colégios de Aplicação, digo, vinculados às universidades públicas - e que dão, evidentemente, um acesso privilegiado às próprias universidades.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Esse é um ponto importante, mas temos vestibulares, hoje, para esses Colégios Militares no plano de segundo grau. Sem dúvida alguma, estamos a falar é de um déficit geral de todo o sistema. E tudo indicaria que deveríamos melhorar, e melhorar significativamente, o modelo do próprio ensino público nesse plano.

Mas veja o que está no debate travado no Rio Grande do Sul:

Muitos dos candidatos beneficiados pela reserva de vagas possuem um bom padrão aquisitivo e são oriundos das melhores escolas públicas federais, estaduais da capital e, por isso, inclusive, das melhores escolas existentes: Colégio Militar, Colégio Aplicação, Colégio Tiradentes, Instituto de Educação General Flores da Cunha, Escola Estadual Florinda Tubino Sampaio, entre outros.

Então, o próprio critério – é importante destacar isso – da escola pública, quando aplicado a determinadas unidades da Federação, ele próprio se revela discriminatório, porque sabemos que há um esforço muito grande, em alguns Estados, para que os filhos estudem nessas escolas públicas: escolas técnicas federais, em alguns Estados, e esses

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3152457.

colégios de aplicação. E dá-se, então, o fenômeno que chamei, na outra feita, da eventual perversão, que é o estímulo de usar o caminho facilitário das cotas agora. Aí, realmente, as cotas se transformam na discriminação em reverso.

Presidente, então, votarei na linha também do desprovimento do recurso, porque o programa está se encerrando, mas acredito que esse programa exija meditação, como exige meditação, realmente, esse modelo caro, oneroso da universidade pública.

Nós falávamos aqui, quando discutíamos o ProUni, que, na escola pública brasileira, universitária, nós temos uma relação de seis alunos por professor, o que é uma média – explico um pouco, Ministro Lewandowski, também a questão salarial –, enquanto a média europeia, por exemplo, é de pelo menos um professor para cada quatorze alunos. Veja, portanto, a disparidade que também aqui se acentua.

Mas esse caso do Rio Grande do Sul está naquela zona grise, na situação limítrofe, porque a escola pública do Rio Grande do Sul não é escola pública de qualquer lugar. É essa escola pública de que estamos a falar, que pode levar a essa perversão, estimular, na verdade, não uma política compensatória, que é necessária, dentro do quadro, mas pode estimular uma atitude arrivista, de aproveitar-se do modelo para aboletar-se em vagas, fugindo à concorrência legítima. Era correto que um aluno de uma escola pública como essa concorresse normalmente no concurso universal: o vestibular.

Portanto, com essas ressalvas, Presidente, eu acompanho também o voto do eminente Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3152457.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Senhor Presidente, eu gostaria de voltar brevemente ao tema, mas para chamar a atenção para um aspecto.

O impetrante, nesse caso, toda a sua petição é permeada pela alegação de que ele está sendo discriminado. Mas eu cito trechos aqui para provar. Vejam Vossas Excelências os seguintes trechos que vou ler aqui:

Frisa-se que a absurda Decisão nº 134 cria regalias em favor dos candidatos ao vestibular que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas federais, estaduais ou municipais, garantindo-lhes, por via transversa, a reserva de vagas, mesmo sabendo do índice de analfabetismo do País. Vejam a gravidade dessa afirmação.

Escolas públicas federais, estaduais ou municipais significam, ou se equiparam, ou são responsáveis pelo analfabetismo. Isso está na petição inicial.

E prossegue: tais decisões como esta devem ser encaradas como verdadeiro pacto de mediocridade. É a velha alegação de que a inserção de minorias no sistema de ensino, até hoje restrito a uma pequena elite do País, resultaria em mediocridade. É absolutamente contraditório, numa ação como esta em que se alega ser vítima de discriminação, ao mesmo tempo, trazer considerações dessa natureza. Vejam como a sensação de pertencimento a um pequeno grupo, ou a membro de um pequeno santuário está presente nisso. Ou seja, este lugar é reservado a mim, a meu grupo, a minha casta. Não há lugar para se destacar parcelas, fazer reserva de vagas nesse nicho para qualquer outro segmento social.

É um absurdo o que se lê aqui nessa petição. Simplesmente absurdo. Mas isso não é novidade alguma para mim. Isso se lê no Brasil, isso emanou de várias associações universitárias do País nesses últimos anos. Esse discurso absolutamente inaceitável vem sendo reproduzido na mídia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402653.

do País nos últimos anos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, só para deixar claro que se recorre – e o recurso extraordinário que está sendo apreciado – da decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um recurso extremamente cuidadoso, tanto que é uma decisão extremamente cuidadosa. Tanto o Relator, o Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, quanto a Redatora para o acórdão, já aqui citada no voto da Ministra Rosa Weber, Juíza Maria Lúcia, primaram por argumentos extremamente cuidadosos do ponto de vista jurídico. Quanto à *causa petendi*, os argumentos são lançados e cabe ao juiz apreciar.

Agora, o dado importante que o Tribunal ressaltou, e que nos faz, realmente, refletir, é este o de que, a despeito da ideia de ações afirmativas ou da reserva de vagas, continua a haver um concurso, e ele vai se dar entre aqueles que apresentem o melhor resultado.

Em relação ao caso da UnB, eu já tinha apontado os sérios problemas daquele tribunal racial – hoje objeto de glosa e objeto até de chacota.

Em relação aqui, ao caso do Rio Grande do Sul, é o debate sobre esse tipo de escola pública. De fato, onde nós temos esse Colégio de Aplicação, talvez, o Colégio seja, inclusive, mais elitista do que as escolas privadas. É assim na Bahia, é assim em alguns outros Estados. E, a partir daí, reservam-se vagas para esse grupo, que, obviamente, terá facilidade de acesso, um treinamento todo ele excepcional, até porque é um modelo experimental.

De modo que, com essas considerações, Presidente, entendo que, em casos que tais, nós temos de estar dispostos a, eventualmente, examinar a discriminação em reverso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402653.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, quando apreciamos o pedido formalizado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não adentramos a questão tratada neste Recurso Extraordinário. Pronunciamo-nos quanto ao sistema de cotas, considerada a raça, e, então, aludimos, até mesmo, à problemática do gênero na referência à Lei nº 9.504/97, que disciplina as eleições.

Presidente, digo que está em jogo definir-se se há como, sob o ângulo constitucional – porque não existe lei específica versando a matéria –, distinguir egressos de escolas públicas e egressos de escolas privadas, e parece que esta ação desmente aquela máxima popular, segundo a qual "pagou passou". Colho, da sentença, alguns dados: o impetrante – e houve a concessão da ordem em primeiro grau – obteve média de 566,44 pontos e ficou na centésima trigésima segunda posição na classificação geral do Curso de Administração noturno. Esteve inscrito no rol daqueles que concorreriam ao denominado ingresso universal. Para esses candidatos, houve a oferta de 112 vagas, de um total de 160 existentes. O impetrante não foi aprovado. Já, aqui, vejo não existir proporcionalidade, presente o sistema de cotas, no que reservado, para o ingresso universal, 112 vagas de um total de 160. Ou seja, visando implementar o desejável tratamento igualitário, houve, para certo segmento, reserva de cerca de 30% das vagas. Quanto ao sistema de cotas, a reserva de vagas, doutrinadores apontam a razoabilidade – Luís Roberto Barroso –, tendo em conta a percentagem de 10%.

Mas prosseguiu o prolator da sentença:

> "De sua vez, o Quadro de Lotação dos Candidatos em 1ª Opção (fls. 46-50)" – 1ª opção, a opção universal – "revela que o primeiro colocado aprovado pelo acesso universal obteve 694,86 pontos, e o último, 573,70; o primeiro aprovado para as vagas destinadas aos egressos do ensino público (cotas exclusivamente sociais)" – e aqui o fator seria a origem quanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2114911.

> ao ensino fundamental e o ensino médio – "obteve 573,51 pontos," – o primeiro aprovado – "e o último, 525,05; o primeiro aprovado para as cadeiras destinadas aos egressos do ensino público e autodeclarados negros (cotas raciais) obteve 527,26, e o último, 463,61 pontos."

Reafirmo que não se faz em jogo o que decidimos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, quando tratamos apenas do ângulo racial, para corrigir, como ressaltei, desigualdade que vem se perpetuando no tempo. Aqui se faz em jogo o fator de discriminação, que é a origem: escola pública e escola privada.

Indago, Presidente: presumindo-se o que normalmente ocorre, presumindo-se que a Administração Pública, o Estado, preocupa-se com a boa formação dos alunos nas escolas públicas, é possível ter esse fator como consentâneo com a Constituição Federal? A meu ver, não, Presidente. A discriminação não se justifica. Demos passo largo no tocante ao problema racial, mas o fizemos tendo em conta algo muito específico: a discriminação do negro. Podemos cogitar de discriminação, presente a opção – e, na escola pública, não estão apenas os menos afortunados – pela escola pública ou privada? Caso assente ser harmônico com a Constituição Federal esse fator de discriminação, estaremos, de certa forma, censurando o próprio Estado, no que mantém essas escolas públicas. Estaremos reconhecendo a falência do ensino público fundamental e médio, em contraste com as universidades públicas.

Não posso presumir que o ensino público fundamental e médio não viabilize o acesso ou o concurso em igualdade de condições, considerados os candidatos em geral e, portanto, também os egressos das escolas privadas.

Por isso, estou convencido de que não cabe estabelecer a distinção. E não sei quantas outras distinções, por exemplo, considerada a renda familiar, poderão ser estabelecidas para afastar-se o critério do tratamento igualitário. Este critério é a regra: o concurso em igualdade de condições, sobressaindo o mérito dos candidatos. Sabemos que o acesso à universidade pública se faz em uma via muito afunilada, uma via de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2114911.

concorrência maior, ante as vagas ofertadas e a gratuidade.

Peço vênia, Presidente, à maioria já formada, para distinguir as situações enfrentadas. Uma coisa é ter-se a busca do tratamento igualitário, presente a raça e até mesmo o gênero, como ocorreu no campo eleitoral. Algo diverso é passar-se a distinguir conforme a escola de origem e entender-se que, em se tratando de escola pública, no que deve proporcionar ensino até mesmo de melhor qualidade, tem-se algo a justificar o tratamento diferenciado no tocante ao vestibular.

Provejo, Presidente – ressaltando, inclusive a proficiência da sustentação feita da tribuna pelo ilustre advogado do recorrente –, o recurso extraordinário interposto. Faço-o para restabelecer a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Porto Alegre e, portanto, conceder a segurança, concorrendo, o impetrante, também, às vagas que, na percentagem de trinta por cento, se fizeram reservadas aos egressos da escola pública.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2114911.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

DEBATE

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Senhor Presidente, gostaria de acrescentar um pequeno dado, mas me referindo ao voto do Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ao que disse, não, Excelência, é voz isolada.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Faz parte do debate, Ministro.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência não precisa se opor a minha fala.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Eu quero trazer um dado que, acho, não foi debatido aqui ainda.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sei que Vossa Excelência jamais concordará com o que acabo de veicular.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Por isso é que eu quero externar e trazer um dado à Corte.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Por isso é que não otimizamos o tempo, porque nos perdemos em discussões, muito embora a matéria esteja praticamente decidida.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Mas essa é uma discussão importantíssima, Ministro Marco Aurélio. Eu conheço muitíssimo bem a literatura sobre esse tema e já, não só, escrevi como leio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402654.

com muita... com muita...

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Admito que Vossa Excelência tenha conhecimento maior do que o conhecimento dos seus pares, mas, nem por isso, Vossa Excelência pode impô-lo.

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - Não, eu não estou rebatendo Vossa Excelência, estou simplesmente trazendo à consideração da Corte.

Senhor Presidente, sobre essa questão, os dados, os estudos feitos nos últimos trinta, quarenta anos, no nosso País e fora do nosso País, é bom não esquecermos, que a questão racial no Brasil é estudada de maneira muito mais consequente fora do Brasil do que aqui, porque nós aqui no Brasil sempre tivemos a tendência a escamotear essas questões, não é isso? Mas o que quero dizer é que os fatores racial, social, econômico se mesclam a mais não poder nessa questão. Quando examinamos a composição étnica das universidades brasileiras, sabemos muito bem que o fator racial ali está presente, mas, com certeza, também, o fator econômico.

É muito ilustrativo, neste caso, o fato de que o impetrante, ele que execra a escola pública, é importante ver o percurso dele: estudou em escola pública num determinado ciclo, em escola privada, paga, provavelmente muito cara, para ter acesso a um pequeno nicho, não é?

Então, eu entendo não haver como sustentar a tese de que, resolvida a questão racial na ADPF nº 186, nós devamos esquecer os aspectos econômicos e sociais. Falar em escola pública, escola secundária no Brasil hoje significa falar em uma composição majoritariamente pobre, de pobres; eis o aspecto econômico. E falar, também, em negros e mulatos. São esses dados.

Um outro dado muito importante que eu gostaria de citar, de um magnífico livro escrito pelo Professor Edward Telles, da Universidade de Princeton. Ele fez um estudo minucioso sobre essa relação entre o econômico e o racial no Brasil. E chegou a algumas constatações. O livro é

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402654.

de quatro, cinco anos atrás. Eu tive a honra de prefaciar esse livro. E ele chega a seguinte conclusão: não há, basicamente, diferença, na desigualdade brasileira, entre negros e mulatos; é apenas uma espécie de sensação, por parte de parcela da sociedade brasileira, de que há essa hierarquização, mas, quando se cuida de tratar da desigualdade econômica, esses estratos sociais estão ali, quase na mesma posição. É um livro magnífico que trata de tudo isso que temos debatido aqui nesta sessão e na assentada anterior. E eu acho que essas questões não podem ser desvinculadas, porque elas estão evidentemente imbricadas: social, a origem do estudante. Infelizmente, assim o é, porque não o era há trinta, quarenta anos atrás. Como todos sabemos. Muito provavelmente nesse Colegiado aqui deve haver alguns, como eu, egressos da escola pública

Essa não é mais a situação do nosso País.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, só para deixar clara essa questão, parece-me – o que marcou o voto do Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores, nesse caso – que a conclusão é a de que o programa de ações afirmativas, segundo a sua visão, teria que ter base em particularidades socioeconômicas, e que isso faltava ao modelo.

O que se percebe, é bom que se diga, é que o próprio modelo da escola pública universitária é discriminatório. Nós tivemos a oportunidade de discutir nas assentadas anteriores. Por que a escola privada tem tantos alunos pobres? São os alunos que trabalham e que têm cursos noturnos. Vejam, dados recentes, até os anos 70, no Brasil – a cidade que talvez tenha mais marca da presença negra no Brasil, Salvador –, não havia escola universitária noturna. As escolas públicas eram todas diurnas, o que já envolve um problema sério, não é, por quê?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Vossa Excelência observou isso no seu voto.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Porque estudar na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402654.

escola pública e não trabalhar significa ter alguém para sustentar, uma vez que também nós não temos um sistema de estipêndio, de bolsa, que permita esse adequado modelo que daria sustentação a essas pessoas. O modelo alemão, por exemplo, envolve um sistema de bolsas, o *BAFöG*, que permite que o estudante colha, a título de subsídio ou de empréstimo, e isso é dado de forma ampla. Quer dizer, o fato de existir vaga, não significa, necessariamente, que essas pessoas, para lá, candidatar-se-ão, em função de uma série de limitações.

Agora, a questão que está se colocando aqui é de índole, inclusive, fática. O fato de, especialmente, na capital, Porto Alegre, haver uma série de colégios de elite públicos, por razões as mais diversas, e o modelo da Universidade do Rio Grande do Sul ter adotado o critério de cotas, voltado para a escola pública. Em geral, talvez, isso fosse correto em todo o Brasil, mas, aqui, já se revela uma peculiaridade. E, para isso, é que se está chamando a atenção e a possibilidade de que nós tenhamos a chamada discriminação em reverso. É esse ponto importante que se tem que fixar.

E, por conta disso também, eu trazia um outro dado que aflora numa matéria publicada no Zero Hora, no Rio Grande do Sul, que dizia que, a despeito da oferta de vagas para esse sistema de cotas, especialmente a cota racial, no Rio Grande do Sul, em razão desses embates no próprio âmbito da sociedade, temos tido uma não utilização dessas vagas. Por quê? Porque começa a criar um tipo de constrangimento ou de discriminação daqueles estudantes que se valem do modelo de cotas, ou que também não é um dado positivo em termos de integração. Então, são dados importantes, que devem ser levados em conta.

Eu desprovejo o recurso, tendo em vista que o programa já está se concluindo – são cinco anos –, mas me parece ser um tema que tem de se levar à reflexão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3402654.

09/05/2012 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) -Confesso, aos senhores Ministros, que, quando da nossa última decisão, especificamente sobre cotas raciais, as duas últimas - a da ADPF nº 186, relatada pelo Ministro Lewandowski, e a da ADI da ProUni, relatada por mim mesmo -, me surpreendi com a reação de um grande número de missivistas nos jornais, dos usuários da internet, mais de perto, das redes de comunicação social, *e-mails* que recebi, deixando-me intelectualmente, pelo menos, incomodado, porque as críticas se faziam numa direção clara: o Supremo decidira não só à margem da Constituição, **a latere,** mas contra a Constituição, o que me obrigou a reestudar a matéria, a repensar, fazer pesquisas no Brasil, no exterior, buscar a base de inspiração no mundo ocidental, e também na Índia, das chamadas cotas étnicas - aqui nós chamamos de raciais -, para ver até que ponto eu deveria me reposicionar, ou não, na audiência de hoje. Mas também confesso que, do rastreamento que fiz na nossa Lei Maior, uma nova visitação aos dispositivos do Texto Magno e, dessas reflexões e pesquisas, só fiz robustecer o ponto de vista que já externei, que me pareceu tecnicamente fundamentado, na linha do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, sobretudo, e dos que seguiram o entendimento de Sua Excelência.

Desde aquela causa do ProUni, aquela ADI, já há algum tempo - estava, até semana passada, sob vista do Ministro Joaquim Barbosa -, que eu me desligara do tema na convicção de que não havia dúvida quanto à constitucionalidade do instituto das cotas raciais ou das políticas públicas afirmativas. Mas agora fiquei confortado, reconfortei-me e confirmei que, na base da inspiração, no mundo inteiro desses mecanismos restaurativos ou compensatórios de desigualdades histórico-culturais, alcançando, por modo preconceituoso, discriminatório, os seguimentos conhecidos - dos negros, das mulheres, dos portadores de deficiência física, dos homoafetivos, dos índios, etc -, volto a dizer, busquei a base de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

inspiração e encontrei, especificamente nos caso dos negros - nos Estados Unidos me parece que isso é muito claro: as cotas foram instituídas - as chamadas raciais - para tentar dissociar um raciocínio, um juízo coletivo automático entre a cor da pele e a função subalterna, ou até inferioridade mesmo como ser, como ser humano. E se dizia - e o tempo comprovou que a base de inspiração era não só jurídica como, tecnicamente, digamos, psicossocialmente justificada - com o tempo, a sociedade americana de tanto ver as pessoas, os negros ocupando postos de comando, de proa, de vanguarda, de liderança na política, nas profissões liberais, nas artes, na televisão, no cinema, no rádio, aquele *link*, aquele vínculo funcional automático experimentaria um processo de fragilização, ou de desfazimento mesmo. Na base da inspiração das políticas públicas afirmativas de natureza étnica, estava essa preocupação de, ao longo de vinte, trinta anos, levar o imaginário coletivo, o inconsciente coletivo a já não fazer essa associação automática. Para lembrar uma frase antiquíssima de Abraham Lincoln: não associar o negro com o engraxador de sapatos; outros dizem engraxate, mas dizem que engraxate é galicismo, o certo é engraxador mesmo. Claro que elas foram concebidas também como um rito de passagem, mas um rito de passagem necessário. Será que aqui no Brasil foi diferente? E, aí, comecei a estudar a diferença entre cotas sociais e cotas raciais. Enquanto o pobre é discriminado por algo externo a ele mesmo, à sua anatomia - que seria a falta de anel no dedo; de canudo de doutor debaixo do braço; ou um automóvel último tipo; ou uma casa residencial suntuosa, luxuosa; ou uma conta bancária polpuda; roupas; nível de vida -, o negro é discriminado por algo interior a ele: a cor da pele. Isso é completamente diferente, é como se padecesse de um déficit congênito, inato, de hipossuficiência ou de indignidade.

E curioso nessas minhas tentativas de aprofundar o estudo do tema, encontrei um trecho de Augusto Comte surpreendente. Ele disse:

"Nessas condições, nunca pode constituir a escravidão, senão uma monstruosidade social, originada da infame opressão" - aí, me parece um equívoco ele passar a dizer, um equívoco neurocientífico e quântico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

também - *"que a raça branca (inteligente) exerceu sobre a raça negra (amante)."* - Ele estabeleceu um hierarquia entre os não negros e os negros - *"abusando de um poder que a humanidade desenvolveu para a comum felicidade de ambos, mediante digno concurso delas"*.

Comentando esse texto de Augusto Comte, Miguel Lemos, no livro "Positivismo e Escravidão Moderna ", Rio de Janeiro, diz que:

"Na linguagem de Augusto Comte, a raça inteligente é a raça branca, em que predomina o desenvolvimento intelectual, e a raça amante ou afetiva é a raça negra, porque predomina o sentimento."

Mas, em compensação, Joaquim Nabuco, ao falar da escravidão, foi mais presciente do que Augusto Comte.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sim. O abolicionismo. E esse pernambucano genial, falando sobre o instituto da escravidão quanto à permanência das suas sequelas, dos seus efeitos perniciosos e deletérios, disse o seguinte:

"A abolição completa da escravidão exige a reforma individual de nós mesmos" - não é só a mudança de comportamento, não, é a mudança como pessoa -, "do nosso caráter, do nosso patriotismo, do nosso sentimento de responsabilidade cívica. É o único meio de suprimir, efetivamente, a escravidão da constituição social. A emancipação dos escravos é, portanto, apenas o começo" - é por isso que, hoje, estamos falando aqui, em pleno Século XXI, de ações afirmativas - *"de um Rinnovamento."*

Ou seja, ele tinha plena consciência de que o problema era cultural. E cultura não é outra coisa senão hábito coletivo. E, se para se romper com o hábito individual é difícil, imaginem para se romper com o hábito coletivo.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Sem dúvida.

Então, quando a Constituição tratou o tema da racialidade, notadamente negra, por um prisma emancipatório, mais do que isso, promocional, e dizendo que o racismo era normatizado na perspectiva do repúdio, no âmbito das próprias relações internacionais do Brasil - daí por que o Ministro Celso de Mello apropriadamente invoca decisões e normas de Direito Internacional, decisões de tribunais de direitos humanos...

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Quando a Constituição coloca o repúdio ao racismo ao lado - artigo 4º, VIII - do repúdio ao terrorismo, quer dizer, a Constituição foi radical intencionalmente porque ela queria infletir sobre essa cultura racista, deletéria, perniciosa.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Pois é, que renitentemente se manifesta entre nós.

Aí a Constituição avançou para dizer que o racismo era crime, já no artigo 5º, XLII, para dizer *"a prática do racismo constitui crime"* - e foi além - *"crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"*. Ou seja, reconhecimento da renitência do racismo como traço cultural brasileiro, porque presente ali naquelas relações de base. Quais são as relações de base caracterizadoras do caráter de um povo, da alma coletiva? As relações de base são aquelas que se passam nos espaços institucionais de que a sociedade se compõe: escola, igreja, família, empresa, condomínio, partido, sindicato, repartição pública; e, por extensão, os espaços físicos de aglomeração humana: shoppings, por exemplo, rodoviárias, aeroportos, cinemas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

E o fato é que, no âmbito dessas relações institucionalizadas da convivência humana, a cor da pele é um elemento de desigualdade, de desigualação por baixo. Daí por que a mesma Constituição, já no artigo 23, erige como política pública o combate aos fatores de desigualdades. No artigo 23, diz a nossa Lei Maior didaticamente: *"X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos"*. E social aqui é mais do que social, é comunitário, porque, desde o preâmbulo, que a Constituição faz a diferença entre o social e o racial. Desde o preâmbulo a Constituição fala de bem-estar, por exemplo. É no plano social: bem-estar físico. O bem-estar vai ser objeto do artigo 6º: educação, saúde, transporte, moradia, lazer. Mas a Constituição não se contenta com o bem-estar, como não se contentou em proibir o racismo e criminalizá-lo. Erigiu o combate ao racismo ao patamar de políticas públicas imperiosas, imperativas.

A Constituição, depois de falar de bem estar, salta para falar de sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Esse discurso é repetido. Atentemos para o artigo 3º, diz a Constituição: *"Art. 3º - Constituem objetivos da República Federativa do Brasil:"* - é, por isso, que eu estou rastreando, passando em revista - permitam-me uma coloquialidade da metáfora: "desfilando pela passarela da Constituição" - para rebater a opinião dos que dizem que nós decidimos, não só **a latere** da Constituição, como contra ela.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Veja Vossa Excelência, é claro que depende da objeção que se levante, mas aqueles que defendem o critério socioeconômico não estão excluindo o critério racial.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Perfeito, Vossa Excelência não exclui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A questão é delicada, e nós vimos neste exemplo, agora, do Rio Grande do Sul. Numa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

teoria dos jogos que a sociedade acabará por utilizar, é, eventualmente, fazer aquilo que eu chamei de uma possível perversão, especialmente diante da falta de nitidez do próprio critério racial. Quem examinou os casos da UnB e viu o constrangimento. Quando se fala de um tribunal racial e dos gêmeos univitelinos, um classificado como branco, outro como negro, para esse tribunal, pode imaginar que isso se comete numa universidade, e que pessoas possam, eventualmente, fazer toda a caminhada numa escola privada, tendo as melhores condições, e depois se apresentar como negro na universidade e passar por esse teste.

Então, veja, a questão é delicada, num país com o grau de miscigenação – e tem que se reconhecer. E vimos, agora, com os exemplos do Rio Grande do Sul, em que cinco, seis, dez escolas públicas de nível médio são consideradas escolas excelentes.

Por outro lado, a despeito de ter dobrado o orçamento da escola pública, nós continuamos carentes de vagas nessa escola. Nós falamos de 1.800.000 estudantes nas escolas públicas. E, veja, eu tenho dados, Presidente, que impressionam, dados de 2010, nível de renda na escola pública, em que nós estabelecemos que não pode cobrar sequer taxa de matrícula, sequer pode cobrar um diploma e sequer pode cobrar um curso de especialização. Veja, classe A, 2010, 15% dos estudantes; a chamada classe A, portanto, a renda altíssima no País; classe B, 41, 1%. Portanto, algo em torno de 55%, vamos dizer assim, pertencentes às camadas mais ricas da população, e essa gente não paga nada à universidade. Quer dizer, a perversão começa aqui, do modelo obrigando o sujeito a buscar ou o FIES, o pobre, ou o ProUni, para a escola privada.

Então, é essa questão que está posta, e foi bom que se tivesse discutido por último este caso, porque se fosse uma escola pública em qualquer lugar do país, talvez, nos pudéssemos dizer: "Mas e o sujeito que vem do Pedro II, o sujeito que vem dessas escolas de elite de Porto Alegre, de excelência, escola pública, e depois goza desse benefício". Faz sentido?

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Não, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

minha critica não se dirige a Vossa Excelência, pelo contrário Vossa Excelência, constitucionalista que é, faz essas distinções mais sutis com toda propriedade.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Falando da defesa da sua indignação, e que foi a minha também, o que temos verificado é que o Supremo Tribunal Federal tem, como matéria prima do seu trabalho diuturno, a Constituição Federal, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, evidentemente, que a dialética da ciência jurídica admite essas contraposições, essas posições que não são convergentes com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sucede que, inúmeras vezes, essas vozes, elas são exteriorizadas por pessoas que não têm o hábito do manejo da Constituição Federal. Então, nós não podemos, a partir de dados excepcionais, firmarmos uma regra à luz do preceito constitucional. Então, o que que nós decidimos aqui contra a Constituição? Absolutamente nada. O que a Constituição estabelece é que os iguais devem ser tratados como iguais, e os desiguais como desiguais, à medida em que se desigualam no mundo inteiro. Esses fatores sociais, essas minorias que têm essa trajetória tortuosa são amparados pela doutrina de elite. Agora, se, eventualmente, eu estudei no Pedro II e consegui chegar a uma universidade pública, eu tive uma grande sorte abençoada por Deus. Mas a grande verdade é que a maioria dos meus Colegas não conseguiram chegar à universidade pública.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Portanto, só não perder de vista que o princípio de igualdade pressupõe igualdade fática, daí a necessidade de examinar esses fatos. Do contrário, nós corremos o risco de fazer a revisada igualdade ideológica; o que não é do que cuida o texto constitucional.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Ainda semana passada, eu li, num jornal de grande circulação, uma frase do Ministro Cezar Peluso, colocada em realce, em que Sua Excelência pegou o espírito da Constituição à unha, a muque; penetrou na carne do real

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

constitucional normativo. Eu sei que o mundo do ser é um e o mundo do dever ser é outro - estou falando metaforicamente. Quando o Ministro Cezar Peluso falou mais ou menos isso: falar de igualdade é muito bom, é fácil, desde que haja igualdade de oportunidade no ponto de partida. Quando não há igualdade de oportunidade no ponto de partida, o que faz o Direito? Compensa desigualdades factuais com desigualdades jurídicas. A resposta do Direito a desigualdades factuais que instabilizam temerariamente a vida social só pode ser uma desigualdade jurídica para restabelecer o equilíbrio da sociedade. Foi o que o Ministro Cezar Peluso disse, eu até o cumprimentei antes de virmos aqui, ainda semana passada.

Mas, para terminar, a Constituição diz algo de que o Ministro Gilmar Mendes, das sobejas demonstrações de pleno conhecimento, diz: construir uma sociedade livre, ou seja, em que o valor fundante seja a liberdade libertária; constitucionalismo liberal, justa, sociedade igualitária, inclusão social, constitucionalismo social socioeconômico, distribuição de patrimônio e de renda, e solidária. É uma terceira fase do constitucionalismo ocidental. O constitucionalismo é cumulativo; é crescentemente superavitário em termos de dignidade da pessoa humana. A liberdade ganhou o tônus da igualdade, o adjutório. Até não é nem adjutório, porque há quem afirme - eu também afirmo isso - que, como dizia Santo Agostinho: sem o mínimo de bem-estar material não se pode sequer servir a Deus. Muitas vezes, a igualdade no plano social é condição de desfrute das liberdades asseguradas pela Constituição e chamadas de fundamentais. Mas não basta a igualdade; é preciso a fraternidade, a solidariedade. Esse tipo de constitucionalismo é chamado pelos italianos de constitucionalismo altruísta. É o que diz a Constituição aqui com todas as letras: as cotas raciais, como as políticas afirmativas em geral, se inscrevem nesse âmbito do constitucionalismo mais avançado, mais humanizado, que podemos chamar de fraternal, de solidário, de altruísta.

Daí a diferença entre inclusão social e inclusão comunitária, que a Constituição faz. Se nós formos para o artigo, por exemplo, 203 da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

Constituição, inciso IV, encontraremos:

"Art. 203.

.....

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;".

É uma vida em comum no âmbito das chamadas relações de base, volto a dizer, definidoras do perfil do caráter coletivo.

Se saltarmos, a Constituição é rica de normas que promovem, mais do que a inclusão social, a inclusão comunitária. Comunidade vem de comum unidade, vem de comunhão de vida, de sentimento, de pertencimento às instituições, todas reunidas, sintetizadas no conceito de nação.

Com esse tipo de decisão, Ministro Ricardo Lewandowski, estamos ajudando a construir ou, pelo menos, a reconstruir uma nação brasileira autêntica, com suporte na Constituição.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Ministro, se Vossa Excelência me permitir, creio que muito mais do que uma política social efêmera, ou até uma política de Governo, nós estamos sufragando uma verdadeira política de Estado, ou seja, uma política permanente para a redenção daqueles que historicamente foram oprimidos.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu acho que Vossa Excelência, inclusive, fez bem ao iniciar o seu voto se referindo a essa preocupação quanto à eventual incompreensão em relação às nossas decisões, porque nós devemos ter essa preocupação.

Aquele dado revelado, por exemplo, em relação à matéria do Zero Hora – no contexto exatamente desse caso, caso do Rio Grande do Sul – mostra bem a dificuldade de integração se a comunidade não a aceita; se é um negro que goza desse benefício, passa a ser objeto de discriminação dentro da universidade. Então tem de se ter esse cuidado. Esse é um dado importante, tanto é que ele se autodiscrimina, não participando do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

regime de cotas. Então, esse é um dado importante.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - As advertências de Vossa Excelência sempre são válidas. Eu tenho dito aqui que o Ministro Gilmar Mendes tem uma característica: ele sempre puxa o debate para cima, para o alto.

O artigo 230, Ministro Ricardo Lewandowski, diz assim, sobre as pessoas idosas: *"assegurando - às pessoas idosas - a sua participação na comunidade"*. Não é na sociedade, não é uma inclusão social, econômica, financeira, patrimonial, não é. É um sobrepasso. Não é uma proteção, é uma promoção; é um ascenso; é uma elevação. Quer dizer, é diferente; se não entendermos essas diferenças normativas - são sutis, é verdade, da Constituição -, perderemos o ponto hermenêutico.

Aliás, eu também já vinha conversando isso com o Ministro Gilmar Mendes, mais à larga - eu vou concluir. De fato algumas leis são ambiciosas, tematicamente, não é Ministro Gilmar? Elas infletem - uma Lei Maria da Penha, por exemplo - sobre a cultura mesma para mudar não os comportamentos, mas mentalidades, mudar as pessoas, porque, quando as pessoas mudam o comportamento, significa uma viagem sem volta, sem retorno; não tem como voltar, porque é um comportamento muito mais consciente e calçado na Constituição.

Bem, são tantas as diferenças que poderíamos estabelecer, do ponto de vista constitucional, mas concluo dizendo que a Constituição partiu de uma constatação histórico-cultural. Os negros experimentam uma abissal desigualdade; nem as mulheres sofrem tanto quanto os negros, nem os deficientes físicos, nem os homoafetivos, nada, porque eles são desiguais na desigualdade; na própria desigualdade social, eles são ainda desiguais, rasgando um abismo em sua desvantagem profundíssima. Então, é preciso que haja políticas públicas nas políticas públicas; políticas públicas desiguais no âmbito das políticas públicas para restabelecer o equilíbrio das coisas. Agora, nós não podemos dizer que uma política pública antirracista é racista. Fica cômodo o discurso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

(RELATOR) - Se Vossa Excelência me permite, não há uma experiência, deste porte, experiência histórica, de âmbito nacional, isenta de erros. Evidentemente que haverá erros, mas esses erros serão corrigidos na caminhada.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E não serão erros macrodimensionados, contra um segmento inteiro.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - São pontuais.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - São pontuais.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Aliás, o Ministro Gilmar Mendes disse bem isto: no gozo da autonomia das universidades.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - E nós - os que nunca sofremos discriminação, embaraço, percalços no nosso trânsito pelos espaços institucionais de que a sociedade civil se compõe - somos beneficiários históricos, temos um acúmulo incalculável de todos os pontos de vistas, de **superavit** existencial. O fato de não sofrer discriminação já é uma vantagem comparativa, do ponto de vista factual, que não há nem como quantificar ou precificar. E aquele que nunca foi desigualado por baixo, ele nem se considera igual, ele se considera superior. A palavra igualdade só tem sentido para quem sofre discriminação, para quem é desfavorecido por baixo, porque quem é favorecido historicamente, culturalmente, não se considera igual não, considera-se superior. Daí a infâmia de tantas piadas, de tantas comparações detrimentosas contra as pessoas injuriosas, contra as pessoas negras.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

Bem, em suma, peço desculpas aos eminentes Pares, porque, como disse o Ministro Gilmar Mendes, nós devemos nos preocupar, sim, com as consequências sociais, políticas, de nossas decisões. Não para nos tornarmos reféns da opinião pública, absolutamente. Mas o fato é que, nesse revisitar da Constituição, Ministro Ricardo Lewandowski, eu me senti animado a robustecer o ponto de vista de Vossa Excelência e o fiz com certa ênfase, mas porque experimentei um conforto, tanto intelectual, quanto espiritual, em constatar que a nossa Constituição é um atestado eloquente ao desumanismo dos preconceitos. Ela é humanista, por excelência, torna-nos um povo primeiro mundista, juridicamente, e ela mesma se qualifica como um documento civilizado no âmbito das nações de economia desenvolvida e de democracia consolidada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3649956.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 597.285
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECTE.(S) : GIOVANE PASQUALITO FIALHO
ADV.(A/S) : CAETANO CUERVO LO PUMO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRS
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Ayres Britto. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Caetano Cuervo Lo Pumo e, pela recorrida, a Dra. Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal. Plenário, 09.05.2012.

Presidência do Senhor Ministro Ayres Britto. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 2027683